

제23장

조서의 작성 및 변론의 녹음 등

제1절	조서제도	708
제2절	조서의 양식 및 기재사항	716
제3절	조서의 작성방법	729
제4절	조서기재의 이의 및 정정	746
제5절	조서의 증명력	753
제6절	변론의 녹음 등	756

제1절 조서제도

1. 총 설

가. 조서제도의 취지

조서는 구술변론이나 그 밖의 심리에 참여한 법원사무관등이 그 심리의 방식과 내용의 요지를 적은 보고문서의 성질을 가진다. 현행 민사소송절차는 구술주의(민소 134조 1항)와 직접주의(204조)를 기본원칙으로 삼고 있으나, 말에 의한 소송행위는 잊히기 쉽고, 불가피하게 재판부가 변경된 경우에는 종전 소송절차의 경과나 심리과정에서 확인된 사항을 안정성과 명확성을 갖춘 소송자료로 활용하기 곤란하게 된다. 조서제도는 위와 같은 사항을 조서에 확정적으로 기록하여, 소송절차의 안정성과 명확성을 보장하면서 구술주의와 직접주의를 보완하는 기능을 한다. 다만 전자소송의 발전으로 서면 제출이 편리해진 현행 실무상 당사자의 법정에서의 진술을 그대로 조서에 옮겨적는 대신 미리 제출한 소장, 준비서면 등을 진술한 것으로 간략하게 조서를 작성하고, 법원의 석명사항에 대한 답변도 바로 조서에 기재하는 대신 추후 별도의 서면으로 제출하도록 하는 경우가 많아, 효율적인 절차진행과 소송자료의 정리 측면에서 조서와 당사자 제출서면 양자를 조화롭게 활용할 필요가 있다.

나아가 법원이 조서작성에 의한 기록화를 염두에 두어 절차법에 따른 절차진행에 더욱 주의를 기울이게 되고, 조서에 기재할 당사자나 증인 등의 진술에 대한 명확한 확인을 위한 노력을 하도록 하며, 상급법원에 원심법원의 절차규정 준수 여부에 관한 판단자료를 제공하는 것도 부수적인 기능으로 제시될 수 있다.

이러한 기능의 전제는 조서기재의 정확성이므로, 민사소송법은 그 작성업무를 절차의 주재자인 법관으로부터 분리하여 법원사무관등에게 부여하고

(민소 152조 1항), 관계인의 낭독·열람신청권(157조)과 이의제기권(164조)을 보장하고 있다.

나. 변론주의와 조서작성

민사소송법은 변론주의를 기본으로 하므로, 당사자가 변론에서 진술하거나 주장하지 않은 주요사실 등은 판단의 기초로 삼을 수 없다. 비록 당사자가 자기의 주장사실을 준비서면 등에 적어 법원에 제출하였다 하더라도 변론에서 그 서면을 진술하여야 한다. 그렇지 않으면 당해 사건의 판단자료로 채용되지 못하고, 그것이 비록 사실인정의 수단으로 되어 있는 증거자료(예컨대 증인의 진술 등) 중에 현출되어 있다고 하더라도 원칙적으로 이를 판결의 기초로 할 수 없다. 다만 변론에서 명시적으로 진술하지 않았더라도 서증 제출, 증인신청 등 다른 소송행위를 통해 간접적으로 주장하였다고 볼 수 있는 경우도 있으므로(대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결), 소송행위의 취지가 불분명한 때에는 석명권을 행사하여 취지를 명확히 하고(대법원 1993. 3. 9. 선고 92다54517 판결) 필요하다면 진술 요지를 조서에 기재할 수 있다.

앞서 언급한 바와 같이 변론조서는 그 작성권을 법원사무관등에게 부여하고 재판장이 이를 인증하는 의미에서 기명날인하며(민소 153조), 소송관계인에게 낭독·열람 및 이의신청의 기회를 주는 등 여러 조치를 마련하였으므로 사실상 강한 증명력을 지닌다. 따라서 당사자가 자기의 주장사실이나 이를 적은 준비서면을 변론에서 진술하고 그것이 변론조서에 기재되면, 안정적으로 판결의 기초가 될 수 있다. 그러나 변론조서에 기재되지 않은 사항은 변론조서가 갖는 강한 증명력을 깰 수 있는 다른 자료가 없는 이상, 판결의 기초로 삼기 어렵게 된다. 따라서 변론조서에는 당사자가 변론에서 진술한 내용의 요지와 당사자의 주장이 담긴 소장, 답변서, 준비서면 등의 진술 여부와 그 범위가 정확하고 명확하게 적혀 있어야 한다.

또한 변론주의에 의하면 당사자 사이에 다툼이 없는 사실, 즉 자백한 사실에 관하여는 법원이 그에 구속되어 증거에 의하더라도 그와 배치되는 사실을 인정할 수 없으므로 주요사실이나 그 밖에 판결에 영향을 미치는 중요한 사실관계에 대한 자백의 내용과 그 범위도 명확하게 조서에 적지 않으면 안 된다.

증거자료인 증거조사의 결과 역시 법정에서 변론에 상정되고 변론의 대상이 되면 변론조서에 적어야 한다. 변론주의의 원칙상 소송자료와 증거자료는 구별되고, 변론기일은 양쪽 당사자의 출석을 요하는 쌍방심리주의가 원칙임에 반하여 증거조사기일에는 당사자가 출석하지 않더라도 증거조사를 할 수 있지만(민소 295조), 증거조사의 결과에 대하여도 상대방에게 증거항변 등의 변론을 할 기회를 주지 아니하면 부당하므로 변론에 상정할 필요가 있다.

실무에서 증거조사가 변론기일에 변론과 함께 행하여지는 경우에는 증거조사의 완료와 동시에 그 결과에 대한 변론의 기회가 주어지므로 큰 문제는 없다. 이러한 경우, 서증의 인부나 증거항변은 변론조서의 일부인 서증목록의 기재란에 적고, 증인신문 후 상대방 당사자의 증거변론은 변론조서에 적어야 한다.

그러나 증거조사가 변론기일 외에서 행하여지는 경우, 예컨대 변론기일전 증거조사결과, 변론준비기일에서의 증거조사결과(민소 281조, 283조 1항), 증거조사기일이 별도로 지정·시행된 경우의 증거조사조서(297조 1항, 검증·감정 등), 증거보전절차의 기록(382조), 수명법관·수탁판사의 증거조사기록(297조, 298조), 조사촉탁에 의하여 송부되어 온 회신이나 문서의 등본·사본(294조) 등은 이들이 기록에 편철되어 있다는 사실만으로 증거로 채용할 수는 없고 반드시 변론에 상정하여야 한다. 이러한 변론상정절차를 조서에 표현하기 위해서는 당해 증거조사조서나 기록 또는 회신 등이 도착되었음을 알리고 이를 당사자에게 제시한 취지를 적음으로써 족하다. 당사자가 이를

원용한다고 진술하면 아울러 그 취지도 적는다.

다. 직접주의와 조서의 작성

민사소송법에 의하면 변론은 직접주의의 원칙에 따라 심리될 것이 요구된다. 직접주의란 변론에 직접 관여하지 아니한 법원은 판결을 할 수 없다는 원칙이다(민소 204조 1항). 조서를 작성하면서 직접주의와 관련하여 유의할 점은, 변론준비기일을 마친 뒤의 변론기일에는 당사자로부터 진술된 변론준비기일 결과(287조 2항)의 취지를 조서에 기재하여야 하고, 소송계속 중 관여 법원이 바뀐 경우에는 변론갱신절차를 거쳐(204조 2항) 종전 변론결과를 진술한다는 취지를 적어야 하며, 항소심 변론조서에는 당사자가 제1심의 변론결과를 진술하고(407조 2항) 그 뜻을 기재하여야 한다는 것이다.

제23장

조서의 작성 및 변론의 녹음 등

2. 조서작성권

심리에 참여하여 조서를 작성하는 것은 법원사무관등이 행하는 직무 중 핵심적인 부분이라고 할 수 있다. 민사소송법은 변론에 관하여 법원사무관등이 속기·녹음 등 특별한 사정이 있는 예외적인 경우를 제외하고는 변론기일에 참여하여 기일마다 조서를 작성하고, 기일에 참여하지 아니한 경우에도 재판장의 설명에 따라 조서를 작성하여야 한다고 규정하고 있다(민소 152조). 그 밖에도, 법원과 수명법관 또는 수탁판사의 신문이나 심문과 증거조사에 관해서도 같은 방법으로 조서를 작성하도록 하고 있다(160조, 민소규 37조 2항).

신청 또는 진술이 기일 외에서 말로 행하여지는 경우 역시 조서를 작성하여야 하지만(예컨대 소액사건의 제소조서 등), 민사소송법은 위와 같은 조서 형식 외의 서면도 가능하도록 하였다(민소 161조 3항). 따라서 법원사무관등이 양식서류에 대필하고 기명날인하는 등의 방법으로 조서 이외의 서면을 작성할 수 있다.

조서작성권은 공증기관으로서 실제로 기일에 참여한 법원사무관등의 고유한 권한에 속하므로, 절차의 주재자인 재판장은 물론 기일에 참여하지 아니한 다른 법원사무관등에게도 작성 권한이 인정되지 아니한다. 따라서 재판장은 조서의 기재 내용이 그가 인식한 것과 다르다고 하여 법원사무관등이 작성한 조서를 스스로 정정·삭제 또는 가필할 수 없다.

그러나 재판장은 비록 조서작성권을 가지고 있지 않지만 조서의 정확성을 담보하는 의미에서 조서에 기명날인을 하므로(민소 153조), 그 기재 내용에 관한 한 법원사무관등의 인식내용과 재판장의 인식내용은 일치하여야 한다.

다만 재판장은 재판사무에 관한 일반적 감독권을 가지고 있으므로(법조 30조 2항, 27조 3항), 조서의 기재 내용이 재판장의 인식내용과 다르다고 생각되는 경우에 위 권한에 기하여 그 기재 내용의 변경을 명할 수 있다. 이 경우에 그 변경명령이 타당하다고 생각되면 법원사무관등은 이미 작성되어 법원사무관등의 기명날인이 끝난 다음 부분에 “재판장의 명에 의하여, … 부분을 …으로 정정(추가, 삽입, 삭제)”이라고 적어 넣은 후 작성연월일을 적고 기명날인할 것이다. 실무상으로는 위와 같은 경우에 법원사무관등이 조서의 내용을 사실상 수정하여 다시 작성하는 방법으로 정리하는 것이 보통이다. 이에 반하여 변경명령이 타당하지 않다고 생각되면, 위와 같이 적어 넣은 후 다시 그 법원사무관등이 자신의 의견을 적은 다음 작성연월일을 적고 기명날인할 것이다.

한편 법원사무관등의 기명날인뿐만 아니라 재판장까지도 기명날인을 완료하여, 조서의 완성요건이 완전히 갖추어진 이후에는, 공증력을 가지는 조서의 안정성이 우선되어야 하므로 재판장이라 할지라도 그 변경을 명할 수는 없다. 따라서 재판장에 의한 조서의 변경명령이 문제될 수 있는 것은 조서에 법원사무관등이 기명날인하였으나, 재판장은 아직 기명날인하지 아니한 단계에서만이다. 다만 화해·포기·인낙조서와 같이 판결과 마찬가지로 효력이 있는 것에 대해서는 판결경정의 방법에 따라(민소 211조) 재판장의 기명날인

후에도 이를 정정할 수 있다.

3. 조서작성 사무의 변화

현행 민사소송법은 사건의 심리에 관하여 집중심리를 원칙으로 하면서, 불필요한 기일참여로 인한 법원사무관등의 부담과 집중적으로 진행되는 변론(준비)기일 조서작성의 부담을 경감하면서도 조서작성의 정확성을 높이기 위한 조치를 강구하고 있다. 그리하여 일정한 경우에는 법원사무관등의 참여 없이 기일을 열 수 있고(민소 152조 2항, 이때에는 기일이 끝난 뒤에 재판장의 설명에 따라 조서를 작성하여야 한다), 단독사건과 합의사건을 불문하고 대법원규칙이 정하는 바에 따라 당사자의 이의가 없는 한 조서의 기재를 생략할 수 있으며(155조 1항, 민소규 32조), 조서를 대신하여 변론을 기록하는 방법으로 속기와 녹음 외에도 비디오테이프나 디지털파일저장매체 등도 활용할 수 있도록 하였다(민소 159조, 민소규 37조 1항). 이에 관해서는 제6절 참조.

이로써 조서의 작성과정을 보다 탄력적이고 효율적으로 운영할 수 있게 되었고, 아울러 이러한 변화를 바탕으로 하여 법원사무관등이 변론준비절차를 비롯한 사건관리 과정에서 일정한 역할(법원사무관등의 역할에 관하여는 사건관리에규 참조)을 담당할 토대도 마련되었다.

4. 조서의 종류

가. 변론조서

판결절차의 필요적 변론의 경우는 물론 결정절차에서 임의적으로 변론을 연 경우에도 변론조서를 작성한다. 변론기일마다 조서를 작성하여야 하기 때문에(민소 152조 1항) 변론기일의 지정이 있고 그 변경결정이 없는 이상(165조), 기일이 개시되었으면(169조) 양쪽 당사자가 출석하지 아니하거나 연기된 경우 또는 증거조사만을 시행한 경우라도 반드시 조서를 작성하여야 한다. 다만 소송이 판결에 의하지 아니하고 완결된 때에는 재판장의 허가를

받아, 증인, 당사자 본인 및 감정인의 진술과 검증결과와 기재를 생략할 수 있다(민소규 32조 1항 내지 3항).

나. 변론준비기일조서

변론준비절차에서 변론준비기일이 열린 경우에는 그 조서를 작성하여야 한다(민소 282조, 283조). 이 조서에는 당사자의 진술에 따라 공격 또는 방어의 방법, 상대방의 청구와 공격 또는 방어의 방법에 대한 진술을 적어야 하고, 특히 증거에 관한 진술은 명확히 하여야 한다(283조 1항, 274조 1항 4호, 5호). 그 밖에 변론준비절차의 시행결과도 적어야 한다(민소규 71조 1항). 변론준비기일조서에는 변론조서에 관한 규정이 준용된다(민소 283조 2항, 민소규 71조 2항).

다. 증거조사조서

변론기일에 증거조사가 함께 행하여지는 경우에는 변론조서나 그 일부를 이루는 목록 등에 이를 적어야 하지만, 법원 밖에서 증거조사가 행하여지는 경우(민소 297조), 증거보전기일(375조 이하), 수명법관·수탁판사의 증거조사(297조, 313조) 또는 석명처분으로 검증을 하거나 감정을 명하는 경우(140조 1항 4호)에는 별도로 조서를 작성하여야 한다.

라. 화해기일조서

소송계속 중 법원이나 변론준비절차의 재판장등이 따로 정한 화해기일(민소 145조 1항, 286조), 수명법관 또는 수탁판사의 화해기일(145조 2항) 및 제소전화해기일(386조, 387조)에는 화해기일조서를 작성하여야 한다.

마. 판결선고조서

법원은 따로 선고기일을 지정하여 판결을 선고하여야 하고(민소 207조), 변론기일에 판결을 선고하는 것은 위법이다(대법원 1996. 5. 28. 선고 96누 2699 판결. 다만 소액사건은 예외이다. 소액 11조의2 1항). 선고기일에 판결이 선고되면 법원사무관등은 판결선고조서를 작성하여야 하고, 이 조서가 없으면 판결선고가 되었다고 볼 수 없어 그 판결은 효력이 없다(대법원 1967. 11. 17. 자 67마914 결정). 판결선고조서에서 재판부의 법관 표시는 판결서에 표시된 법관이 아니라 실제로 선고기일에 법정에서 선고에 참여한 법관의 성명을 기재하여야 한다.

바. 조정기일조서

조정신청사건이나 소송계속 중 수소법원에 의하여 조정에 회부된 조정사건에서는 그 조정에 관하여 조서를 작성하여야 한다(민조 24조, 28조).

사. 심문조서

심문이란 변론을 열지 않는 경우에 당사자와 이해관계인, 그 밖의 참고인에게 서면 또는 말로 진술하거나 증거자료를 제출할 기회를 주는 절차이다. 결정으로 완결할 사건에서 변론을 열지 아니하는 경우에는 법원 또는 수명 법관이나 수탁판사가 심문을 할 수 있다(민소 134조 2항). 심문을 위해 서면 제출 기회를 부여할 수 있고 기일을 열어 진술 기회를 부여할 수도 있는데, 심문기일을 연 경우에는 심문조서를 작성하여야 한다. 필요적으로 심문을 하여야 하는 경우로는 승계인의 소송인수 시 당사자와 승계인의 심문(82조 2항), 증언거부에 대한 재판 시 당사자의 심문(317조 1항), 제3자에 대한 문서제출명령을 하는 경우에 그 제3자(또는 그가 지정하는 자)의 심문(347조 3항) 등이 있고, 민사집행절차에서도 필요적 심문의 예가 있다.

비송사건절차에서는 심문이 일반적인 심리절차로 규정되어 있는데, 증인

또는 감정인의 심문에 관하여는 필요적으로 조서를 작성하여야 하나, 그 밖의 심문의 경우에는 필요하다고 인정하는 경우에 한하여 조서를 작성한다(비송 14조).

아. 신청조서

신청 또는 진술이 변론 외에서 법원사무관등의 면전에서 말로 행하여지는 경우에는 별도의 조서를 작성하거나, 조서 이외의 서면을 작성한 뒤 기명날인하는 것도 가능하다(민소 161조, 비송 8조, 가소 36조 4항, 5항, 12조). 소액 사건에서 말로 소를 제기하는 경우에는 제소조서를 작성하여야 하는데(소액 4조), 이 제소조서 역시 신청조서의 일종이라 할 수 있다. 신청조서에는 법원사무관등만이 기명날인하면 된다.

제2절 조서의 양식 및 기재사항

1. 총 설

법원재판사무 처리규칙 6조 1항의 위임에 따라 각급 법원이 사용할 문서의 양식 등을 정한 '재판사무에 관한 문서의 양식에 관한 예규'는 각종 조서의 양식 등을 법원전산시스템에 등록된 전산양식의 형태로 정하고 있다. 전산양식이 있는 조서의 경우에는 그 양식을 사용하여야 한다(전산양식예규 2조 1항). 이러한 전산양식 중 법원전산시스템이 출력지원하는 전산양식은 그 시스템 내에서 편집·출력하여 사용함으로써 재판사무의 처리과정 및 관련 사무처리 정보가 법원전산시스템을 통하여 관리, 보존될 수 있도록 하여야 한다(2항).

민사소송법은 152조 이하에서 변론조서에 관하여 상세한 규정을 두고 다른 조서에도 이를 준용하도록 하고 있으므로(민소 160조), 아래에서는 모든

조서의 기본이 되는 변론조서를 중심으로 하여 그 체제, 유효요건 및 기재사항에 관하여 살펴본다.

2. 변론조서의 양식

가. 1기일 1조서의 원칙

법원사무관등은 변론기일에 참여하여 기일마다 조서를 작성하여야 한다(민소 152조 1항). 이를 ‘1기일 1조서의 원칙’이라고 한다. 이 원칙은 1기일의 내용을 소송기록 중에서 용이하게 파악할 수 있도록 조서내용의 일람성을 확보하는 데 그 의미가 있다. 이로써 1기일의 변론진행 경과가 여러 개의 조서로 작성됨에 따라 발생할 수 있는 조서의 법정증명력(158조)의 중복·모순이 방지되어 절차의 안정성과 명확성도 확보될 수 있다. 따라서 기일이 개시된 이상 기일이 연기된 경우 등 조서에 기재할 아무런 실질적 기재사항이 없는 때라도 조서를 작성하여야 한다.

‘1개의 조서’란 물리적 존재로서의 용지의 매수를 의미하는 것이 아니라, 조서의 형식적 요건(민소 153조)을 구비한 1개의 조서를 말한다. 1개의 기일이 사실상 수일에 걸쳐서 실시된 경우에도 1개의 조서만 작성하면 된다. 1개의 기일에 변론, 증거조사, 화해 등 여러 사항이 행하여진 경우에도 1개의 조서를 이루는 것이다.

나. 변론조서의 체제

변론조서의 기재사항 가운데 서증의 제출과 상대방의 인부 등 진술, 그 밖의 증거신청과 채부의 재판에 관한 사항(직권에 의한 증거조사결정을 포함한다)과 증거조사기일의 지정 등에 관한 사항은 목록으로 작성하여야 한다. 이에 따라 ‘재판사무에 관한 문서의 양식에 관한 예규’는 기본적 변론(준비기일)조서[전산양식 A1650, A1650-1, A1651]와 증거조사에 관한 조서(예컨대 증인신문조서[전산양식 A1656], 당사자신문조서[전산양식 A1659], 서증조사조서

[전산양식 A1665]) 및 증거목록(서증목록[전산양식 A1876], 증인등목록[전산양식 A1877])을 따로 작성하도록 하고 있다. 조서작성에 관하여 이른바 사항별 작성방법을 채용한 것이다. 증거목록의 작성과 편철에 관하여는 ‘민사 등 증거 목록에 관한 예규’가 상세하게 규정하고 있다.

대부분의 경우 변론(준비)기일에 증거조사가 함께 시행되고 있으나, 협의의 변론은 증거조사와 구별되므로 그에 관한 조서를 구분하여 작성하는 것이 변론주의의 원칙에도 충실할 수 있을 뿐 아니라, 변론(준비기일)조서 자체에는 당사자의 소송행위나 법원의 소송지휘 및 재판을 그대로 적으면 되지만 증거조사에서는 선서 등 일정한 절차를 요구하는 경우가 있으므로 이를 별도로 나누어 작성하는 것이 조서작성의 능률을 위하여도 합리적이다.

증거조사에 관한 조서와 목록은 위와 같이 변론(준비기일)조서와 분리되어 작성되더라도 변론(준비)기일에 시행된 사항을 적은 이상 변론(준비기일)조서의 일부를 이룬다(민소 154조 2호, 3호). 따라서 변론(준비기일)조서에는 “별지와 같이 증인신문” 또는 “증거관계 별지와 같음(서증·증인등)”이라고 증거조사에 관한 사항을 적어 별도로 작성된 조서 또는 목록과의 연관관계를 명백히 하여야 한다. 아울러 이와 같이 적는 것만으로는 어느 서증목록 또는 증인등 목록에 그 증거조사에 관한 내용이 적혀 있는지가 분명하지 아니하여 각 당사자의 증거목록을 일일이 검토하여야 하는 번거로움이 있으므로, 당사자별로 증거관계가 상이할 경우에는 참고할 증거목록을 명확히 하기 위하여 “서증·증인등” 표시 앞에 반드시 관계당사자와 관련 증거방법을 기재하여야 한다(예: 증거관계 별지와 같음(원고 서증·증인등, 피고 증인등))(조서예규 2조).

변론기일 외에서 행하여진 증거조사의 결과는 구술주의, 직접주의의 원칙상 변론에 상정하는 절차를 거치고 이를 변론조서에 적어야 함은 전술한 바와 같다.

그리고 변론(준비)기일에 화해·포기·인낙이 있는 경우에 그 기일의 조서에는 화해·포기·인낙이 있다는 취지만을 적고, 별도의 용지에 뒤에서 보는

바와 같은 형식적 기재사항과 화해조항 또는 포기·인낙의 취지 및 청구의 취지와 원인을 적은 화해·포기·인낙의 조서를 따로 작성하여야 한다. 다만 소액사건에서는 특히 필요하다고 인정하는 경우 외에는 청구의 원인을 적지 아니하는데(민소규 31조), 그 필요 여부에 관하여는 소액사건심판법 11조의2 3항에서 정한 판결이유 기재 사유를 참고할 수 있다. 화해조서 등을 별도로 작성하게 함은 송달 편의 및 보존기간이 서로 다른 변론조서와 화해조서 등의 보존상 편의 등을 고려한 것이다. 따라서 화해·포기·인낙조서는 ‘재판사무에 관한 문서의 양식에 관한 예규’가 정하는 양식에 따라 변론조서와는 구분하여 작성되고(전산양식 A1690I 등), 화해·포기·인낙조서에도 재판장과 법원사무관등이 기명날인한다(재민 99-7 화해조서등의 작성시 기명날인 여부). 이와 같이 변론(준비기일)조서와 별도로 작성되더라도 이들 조서는 변론(준비기일)조서의 일부를 이룬다고 할 수 있다.

제23장

조서의 작성 및 변론의 녹음 등

3. 조서의 유효요건

조서가 공증문서로서 후술하는 바와 같이 증거력을 가지기 위해서는 일정한 요건을 갖추어야 한다.

첫째로, 원칙적으로 조서는 심리에 참여한 법원사무관등이 심리 또는 변론의 요지를 적기 위하여 직무상 작성한 것이어야 하므로, 이 경우 심리에 참여하지 아니한 다른 법원사무관등이 작성한 조서는 무효로 된다.

둘째로, 조서에는 일정한 형식적 기재사항, 예컨대 사건의 표시, 관여 법관 및 참여한 법원사무관등의 이름, 변론의 일시와 장소 등을 적어야 하며, 이러한 사항이 누락된 조서 역시 그 전체가 무효로 된다. 그 밖의 형식적 기재사항을 누락한 조서는 그로써 조서 전체가 무효로 되는 것은 아니며, 단지 그 누락사항에 관하여 조서에 의한 절대적 증명력이 없음에 그친다.

셋째로, 조서에는 작성명의인인 법원사무관등과 재판장의 기명날인이 있어야 하며, 그것이 없으면 조서는 무효로 된다. 판결선고조서에 판결을 선고

한 취지의 기재가 있고 법원사무관등의 기명날인이 있으나 특별한 사유 없이 재판장의 기명날인이 없다면 이 조서로는 판결선고 사실을 증명할 수 없다(대법원 1955. 4. 7. 선고 4288민상6 판결). 전자문서로 조서를 작성하는 경우에도 전자서명을 누락하지 않도록 주의하여야 한다.

4. 형식적 기재사항

민사소송법 153조는 조서의 형식적 기재사항을 규정하고 있으며, ‘재판사무에 관한 문서의 양식에 관한 예규’는 이들 형식적 기재사항의 기재란을 미리 마련하여 적절히 배열해 놓은 전산양식을 정하고 있다.

조서의 형식적 기재사항은 변론의 형식 또는 방식에 관한 사항으로서, 실질적 기재사항과는 달리 조서에 의해서만 증명될 수 있고 다른 방법에 의한 증명은 허용되지 아니한다(민소 158조). 전술한 바와 같이 이들 형식적 기재사항 중 일정한 중요사항을 빠뜨린 조서는 그 전체가 무효로 될 뿐 아니라, 일단 형식적 기재사항으로 적게 되면 실제 행하여졌는지 여하에 불구하고 그 기재 내용이 절대적 증명력을 갖게 되므로 세심한 주의를 기울여 적어야 한다. 법정녹음 등을 통해 사후적으로 조서 기재의 오류가 확인되는 경우에도 신속하게 조서정정 절차를 이행하여야 할 것이다(조서정정 절차에 관하여는 제4절 3. 참조).

가. 사건의 표시(민소 153조 1호)

사건의 표시란에 사건번호와 사건명을 함께 적는다. 변론이 병합된 때, 반소 등이 제기된 때에는 사건의 표시란에 각각의 사건번호와 사건명을 함께 적는다. 사건표시의 기재가 없어서 어느 사건에 대하여 작성된 조서인지를 판별할 수 없다면 그 조서는 효력이 없다고 보아야 할 것이다.

나. 법원과 법원사무관등의 성명(민소 153조 2호)

당해 기일에 관여한 법관의 이름을 적는다. 법관이 경질된 때에는 그 취지를 기재할 필요는 없고, 그 변론에 관여한 법관의 성명만을 기재하면 된다.

법원사무관등은 그 기일에 참여한 경우에 그 이름을 적어야 한다. 참여하지 아니한 경우에는 그 이름을 형식적 기재사항으로 적지 아니한 채, 참여하지 아니하고 재판장의 설명에 따라 조서를 작성하였다는 취지만을 적으면 된다(민소 152조 3항 참조, [전산양식 A1653]).

이러한 기재로써 법원(재판부)구성의 적법 여부와 법원사무관등의 참여 여부가 증명된다. 관여 법관으로 기재된 이름과 조서에 기명날인한 법관의 이름이 다르면 그 조서는 무효로 된다.

법원사무관등의 이름이 기재되지 않고 아울러 그 참여 없이 재판장의 설명에 따라 기일이 끝난 뒤에 작성되었음을 확인할 수도 없다면 그 조서의 효력을 인정하기 어려우므로, 법원사무관등이 참여하지 않은 기일에 대한 조서에서 민사소송법 152조 3항의 기재사항을 누락하지 않도록 유의할 필요가 있다. 변론조서와 이에 부속되는 화해조서 등을 별도로 작성하는 경우 위 기재사항의 위치가 문제될 수 있으나, 화해조서 등이 독립적으로 송달 및 보존의 대상이 되는 점을 고려할 때 변론조서와 화해조서 등에 각각 위 기재사항을 기재함이 적절할 것이다.

다. 출석한 검사의 성명(민소 153조 3호)

여기서 말하는 검사란 당사자로서 출석한 경우가 아니라 비송사건절차 등에서 검사가 공익의 대표자로서 의견을 진술하기 위하여 출석할 것을 법이 규정한 경우(비송 15조)를 지칭한다. 양식에는 별도의 기재란이 마련되어 있지 아니하므로 당사자 출석란 다음에 이를 적는다. 그러나 검사가 당사자로 참여한 경우(가소 24조 3항, 27조 4항)에는 다음에서 설명하는 당사자로 기재한다.

라. 출석한 당사자·대리인·통역인의 성명과 출석하지 아니한 당사자 성명(민소 153조 4호)

(1) 당사자

독립당사자참가인은 물론이고 보조참가인도 당사자에 준하여 기재할 것이다. 기일에 화해나 조정이 성립되는 경우에 그 화해나 조정에 참가하여 화해조항이나 조정조항에 그 권리·의무가 포함된 자에 대하여는 그를 화해참가인 또는 조정참가인(민소 16조)으로 표시한다.

한쪽 당사자가 다수인 경우에는 출석한 사람과 출석하지 아니한 사람을 구별하여 표시한다. 또한 당사자가 다수이어서 조서의 해당란에 이를 전부 적을 수 없을 때에는 “별지와 같음”이라고 적은 다음 그 명단을 조서의 맨 끝부분에 편철하는 것도 가능하다.

(2) 대리인·통역인·속기자

당사자가 미성년자 등 소송무능력자인 경우에는 그 법정대리인의 이름을 적고 법정대리인임을 덧붙여 적는다.

소송대리인이 다수인 경우에는 당사자가 다수인 경우의 예에 따른다. 당사자 본인과 소송대리인 모두 출석하여 각각 소송행위를 한 경우에는 “원고 (피고) 및 대리인 ○○○ 각 출석”이라고 기재한다.

통역인이 출석한 경우 “통역인 ○○○ 출석”이라고 기재한다. 법원이 조서의 일부가 되는 속기록 작성을 위하여 속기자로 하여금 변론을 속기하게 한 경우에도(민소 159조 1항) 그 사람의 이름을 통역인에 준하여 적는 것이 실무이다. 그러나 조서의 일부가 되는 법정녹음물의 녹음내용에 대한 녹취서 작성(민소규 35조)을 준비하기 위하여 법정에 출석한 경우에는 속기자의 이름을 형식적 기재사항으로 적지 아니한다.

(3) 증인·감정인·당사자신문의 당사자

실무상 증인·감정인 또는 당사자 본인에 대한 신문이 증거로 채택되어 시행되는 경우, 해당 기일조서에는 편의상 그들의 출석 여부도 조서의 당사자

란 다음에 적는 것이 관례이다. 이들의 불출석은 소송비용의 부담 또는 과태료나 감치의 처분을 받게 되거나(민소 311조, 333조), 구인을 당하고(312조), 당사자신문의 경우에는 신문사항에 관하여 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있게 되는 효과(369조)를 가져올 사유가 되기 때문이다.

증인·감정인의 경우 적절한 출석요구가 없었으나 임의출석한 경우에는 “(미송달) 임의출석”, “(송달불능) 임의출석”의 방식으로 기재한다. 이는 소송비용을 계산할 때에 미송달임에도 불구하고 송달료가 계산되는 것을 방지하기 위한 것이다. 재정증인의 경우에는 “재정증인 ○○○ 출석”이라고 기재한다.

(4) 출석·불출석의 기준

불출석이란 기일개시로부터 종료까지 사이에 전혀 나타나지 아니한 경우를 말한다. 따라서 당사자 등이 호명되었을 때에는 재정하지 않았으나 당해 사건의 기일이 종료되기 전에 출석한 경우에는 출석으로 처리할 것이다.

사건과 당사자의 이름을 불러 불출석을 확인한 후 다음 사건을 진행하고 있는 도중 불출석 당사자가 법정에 들어와 사건 진행을 요청하는 경우가 있다. 이미 해당 사건의 기일이 종료된 이상 원칙적으로 소급하여 변론을 계속할 수는 없다. 다만 불출석처리한 양 당사자가 함께 법정에 들어오거나, 출석한 일방 당사자가 법정에서 나가기 전에 불출석처리했던 다른 당사자가 들어오는 경우에는 양 당사자의 동의를 얻어 당일의 기일을 다시 진행하는 방안을 고려할 수 있을 것이다.

일단 출석한 당사자가 기일의 종료선언 전에 퇴정한 때에는 출석 여부에 “출석”으로 기재하고, 변론요지란에 “중도 퇴정”, “출석한 당사자 변론하지 아니하고 퇴정”, “재판장의 퇴정명령으로 퇴정” 등과 같이 적는다. 이는 다음 기일을 위한 통지의 필요가 있는지 여부를 알 수 있도록 하는 데 유용하다.

영상재판, 즉 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 출석하는 경우의 불출석 여부 판단 기준에 관하여는 제19장(기일과 기간) 제6절 2. 나. (2) 참조.

(5) 불출석 사유의 기재

당사자 등에게 적법한 기일통지를 하지 못하였거나, 기일통지 여부 자체를 확인할 수 없는 경우에는 해당자의 이름과 출석 여부 표시 사이에 괄호를 하고 그 안에 “미통지”, “송달불능”, “송달착오”, “보정지연 미통지”, “송달중”, “공시송달기간 미도과” 등이라고 적어 그 사유를 밝히는 것이 관례이다. 이때에는 불출석한 당사자 등에게 쌍불취하 등 기일해태에 따른 불이익이 적용되지 않는다.

증인·감정인 등의 출석을 요하는 경우에도 위와 같은 요령으로 그 사유를 괄호 안에 기재한다. 그러나 이미 채택한 증인에 대하여 증인신청서를 제출하지 않았거나 늦게 제출하여 출석요구를 하지 못한 경우에는 “(절차불이행 미송달) 불출석”, “(절차지연 미송달) 불출석” 등과 같이 기재한다.

(6) 기일불출석의 효과를 위한 기재

민사소송법상 기일불출석의 효과가 발생하려면(민소 148조, 150조 3항, 268조 2항, 3항), 당사자 본인과 소송대리인이 모두 출석하지 아니할 것을 요건으로 하므로 소송대리인이 출석하지 아니하였더라도 반드시 당사자 본인을 호명하여 그 출석 여부를 확인하여야 하고, 대리인이 여러 사람인 경우에는 그 이름을 전부 적고 불출석을 적어야 한다(조서예규 3조, 별표 1 참조).

[쌍방불출석 조서의 기재례]

- | |
|---|
| <p>① 원고와 대리인이 한 사람씩인 경우
원고 및 소송대리인 변호사 ○○○ 각 불출석</p> <p>② 다수의 한쪽 당사자 중 일부와 그 대리인이 출석하지 아니한 경우
원고 ○○○ 및 소송대리인 변호사 ○○○ 각 불출석</p> <p>③ 다수의 한쪽 당사자 전원과 그 대리인이 출석하지 아니한 경우
원고들 및 소송대리인 변호사 ○○○ 각 불출석</p> |
|---|

마. 변론의 날짜와 장소(민소 153조 5호)

민사소송법은 변론의 날짜만을 적도록 규정하고 있으나 그 시각까지도 명시하여 적어야 한다. 실무상 시차제소환이 일반화되면서(민소규 39조) 시각까지도 특정하여 기일을 지정하고 있고, 기일 불출석의 효과와의 관계상 이를 특정하지 아니하면 불공정성이나 불명확성에 대한 문제제기가 가능한 사례가 발생할 수 있기 때문이다. 기일이 자정을 지나서 끝난 경우에는 그 시각도 함께 적는다.

변론의 장소는 법정의 호수까지 명시하여야 한다(법정이 하나밖에 없는 법원에서는 편의상 제1호 법정이라고 적는다). 법원 밖에서 변론(법조 56조 2항)이나 증거조사(민소 297조)를 하는 경우에는 그 시행장소의 지번, 건물소재지 등을 특정하여 적어야 한다.

바. 변론의 공개 여부와 공개하지 아니한 경우에는 그 이유(민소 153조 6호)

변론을 공개하지 아니하는 경우에 그 이유는 변론의 요지란에 적는다. 변론이나 신문의 일부를 비공개로 한 경우에는 그 비공개로 한 부분을 명시하고, 공개를 정지한다는 법원의 결정과 이를 선고한 취지 및 그 이유를 적어야 한다(법조 57조).

제23장

조서의 작성 및 변론의 녹음 등

[조서기재례]

① 재판장

선량한 풍속을 해할 우려가 있으므로 심리를 비공개한다고 결정하고 이를 선고

② 재판장

선량한 풍속을 해할 우려가 있으므로 다음 사항에 관한 심리를 일부 비공개한다고 결정하고 이를 선고

③ 재판장

선량한 풍속을 해할 우려가 있으므로 증인 ○○○에 대한 신문을 별지조서와 같이 일부 비공개한다고 결정하고 이를 선고

이러한 경우에 공개 여부란에는 “법정 비공개”, “법정 일부비공개”, “증인 신문 일부비공개”와 같이 적는다.

실무상 심문실이나 준비절차실에서 변론준비기일을 여는 경우 당사자나 이해관계인 이외의 제3자가 방청을 시도하는 경우는 거의 없다. 이에 따라 공개 여부가 아무런 문제가 되지 않은 상태에서 변론준비기일이 진행되기도 하는데, 명시적으로 비공개 결정을 하거나 제3자의 방청을 제한하지 않은 이상 조서에 공개로 기재하더라도 무방할 것이다.

사. 재판장과 법원사무관등의 기명날인

조서에는 재판장과 법원사무관등이 기명날인한다(민소 153조 본문). 다만 재판장이 기명날인할 수 없는 사유가 있는 때에는 합의부원이 그 사유를 적은 뒤에 기명날인하며, 법관 모두가 기명날인할 수 없는 사유가 있는 때에는 법원사무관등이 그 사유를 적어야 한다(153조 단서).

조서에 대한 기명날인은 전자서명 방식으로 하게 되나(민전 10조 1항), 예외적으로 종이로 조서를 작성하는 경우 날인할 법원사무관등의 인장으로는 사인(私印)을 사용한다(조서예규 7조 1항).

아. 그 밖의 기재사항

법원사무관등이 기일에 참여하지 아니하고 그 기일이 끝난 뒤에 재판장의 설명에 따라 조서를 작성하는 경우에는 조서에 그 취지를 덧붙여 적어야 한다(민소 152조 3항).

‘재판사무에 관한 문서의 양식에 관한 예규’에서 정한 전산양식에 의하면 법정의 형식적 기재사항은 아니지만 조서표지 머리 부분에 당해 법원관청명과 기일의 종류(변론조서)와 차수, 고지된 다음 기일 및 기일시작의 요건(“사건과 당사자의 이름을 부름”)을 적는 난을 두고 있다.

(1) 차 수

변론이 병합 또는 분리된 때에는 기본이 되는 사건의 차수에 따르고 이송 또는 환송 받은 사건의 차수는 이송한 법원 또는 환송전 법원에서 한 변론의 차수에 이어서 표시한다. 상소심의 경우에는 원심의 변론차수에 계속되지 않고 새로 시작한다.

[전산양식 A1651] 변론조서

○ ○ 법 원

변 론 조 서

차

사 건 20 가

판 사

기 일 20 . . . :

장 소 제 호 법정

공개여부 공 개

고 지 된

다음 기일 20 . . . :

법원주사

사건과 당사자의 이름을 부름

원 고

출석

피 고

출석

민소 152, 153, 154

주: 합의부의 수명법관이 변론준비기일을 진행한 경우에는 조서의 형식적 기재사항이나 조서 말미에 “판사”를 “수명법관 판사”로 표시한다.

제23장

조서의 작성 및 변론의 녹음 등

(2) 고지된 다음 기일

이는 변론의 방식에 관한 사항은 아니고 재판의 내용에 관한 사항이지만 (대법원 1969. 6. 10. 선고 69다402 판결), 조서양식에는 ‘형식적 기재사항’란에 ‘고지된 다음 기일’란을 두고 있다. 여기에는 시·분까지 명기한다.

다음 기일을 영상재판 방식으로 진행하는 경우에는 “고지된 다음 기일 2000. 0. 0. 00:00(쌍방 화상장치)”와 같이 일시 뒤에 그 출석유형도 함께 기재하여야 한다(영상재판예규 11조 4항).

5. 실질적 기재사항

민사소송법 154조는 조서의 실질적 기재사항을 열거하고 있는데, 조서에 이러한 사항을 포함하여 변론의 요지를 적는 것이므로, 이는 주요한 사항을 예시한 것에 불과하다. 변론의 요지란, 견해의 대립이 있으나, 당사자와 법원의 소송행위 및 증거조사의 결과 등의 요지를 의미하는 것으로서 그 진행과 실질적 내용을 모두 포함한다고 보아야 할 것이다. 형식적 기재사항과 달리 실질적 기재사항의 기재가 없어도 조서 자체가 무효로 되지는 않는다.

민사소송법이 그 중요성에 비추어 특히 분명히 할 것을 요구하는 사항은 다음과 같다(민소 154조).

- (1) 화해, 청구의 포기·인낙, 소의 취하와 자백(1호)
- (2) 증인·감정인의 선서와 진술(2호)
- (3) 검증의 결과(3호)
- (4) 재판장이 적도록 명한 사항과 당사자의 청구에 따라 적는 것을 허락한 사항(4호)
- (5) 서면으로 작성되지 아니한 재판(5호)
- (6) 재판의 선고(6호)

위 사항을 포함하여 변론의 요지를 조서에 기재하는 구체적 작성방식에 관하여는 제21장(변론), 제22장(사건관리 및 변론의 진행), 제25장(증거조사),

제26장(증인), 제27장(서증), 제28장(감정·검증·사실조회), 제29장(당사자신문 및 그 밖의 증거조사)의 해당 부분 참조.

6. 조서의 색지와 규격

조서는 원칙적으로 전자문서로 작성하여야 하고(민전 10조 1항, 민전예규 4조 2항), 규격에 따른 전자문서 생성 기능을 제공하는 전자소송시스템의 조서작성프로그램을 사용하는 경우(민전예규 69조 1항) 용이하게 문서명을 확인 또는 검색할 수 있으므로 용지 색깔로 문서종류를 구분할 필요가 없다. 예외적으로 법원사무관등이 종이로 변론조서, 판결선고조서, 변론준비기일조서, 증거조사조서, 화해기일조서, 조정기일조서, 심문조서 등을 작성하는 경우에는 연두색의 조서용지(색지조서)를 사용한다. 다만 변론조서의 일부를 이루는 증인등신문조서·속기록, 화해기일조서나 조정기일조서의 일부를 이루는 화해조서·화해권고결정조서·조정조서·조정을 갈음하는 결정조서 등은 예외이다. 또한 조서용지로는 A4용지(210mm×297mm)를 사용한다(조서예규 6조, 별표 2, 3). 조서 등 소송서류의 용지는 위와 같은 규격의 용지를 세워서 쓴다(민소규 4조 2항).

제23장

조서의 작성 및 변론의 녹음 등

제3절 조서의 작성방법

1. 기일참여 여부에 따른 차이

법원사무관등은 기일에 참여하여 조서를 작성하는 것이 원칙이다. 다만 변론(준비)기일에서 변론을 녹음·속기하거나 그 밖에 이에 준하는 특별한 사정이 있는 경우에, 그 밖의 기일에서는 단순히 재판장이 필요하다고 인정하는 경우에, 각각 법원사무관등을 참여시키지 아니하고 기일을 열 수 있다(민소 152조 1항, 2항, 283조 2항). 따라서 법원사무관등이 기일에 참여한 경우

와 그렇지 아니한 경우에 조서의 작성방식이 달라진다.

먼저, 법원사무관등이 기일에 참여한 경우에는 자신의 인식에 따라서 조서를 작성한다. 다만 조서가 현실적으로 작성되는 시기에 관하여 보면, 민사소송법이 조서를 기일 중에 법정에서 그 기일의 경과를 시간적 순서에 따라 작성하는 것으로 예상한 듯이 보이지만(민소 157조 참조), 실제로는 법정에서 입시로 기재한 내용을 정리, 보완하여 기일종료 후에 조서를 완성하고 있다.

다음으로, 법원사무관등이 기일에 참여하지 아니한 경우에는 그 기일이 끝난 뒤에 재판장의 설명에 따라 조서를 작성하고 조서에 이러한 취지를 덧붙여 적어야 한다(민소 152조 3항). 이 경우에는 언제나 기일이 끝난 후에 조서가 작성되는데, 조서의 기능과 기억의 한계 등을 감안할 때 재판장과 법원사무관등은 가급적 신속하게 조서가 작성될 수 있도록 노력하여야 한다.

이하에서는 법원사무관등이 기일에 참여하는 경우를 중심으로 살펴본다.

2. 기재방법

가. 총 설

조서의 기재방법에 관하여는 법률상 아무런 정함이 없다. 형식적 기재사항에 관하여는 이미 언급한 바와 같이 '재판사무에 관한 문서의 양식에 관한 예규'에서 정한 전산양식을 사용하여 각 해당 항목을 간단하게 보충 기입하는 방식을 취하고 있으므로 특별한 어려움이 없다.

조서는 법원사무관등이 직접 간결한 문장으로 분명하게 작성하여(민소규 4조 1항) 다른 사람으로 하여금 쉽게 이해할 수 있게 하여야 한다. 조서의 기재에 오·탈자가 있는 경우에는 전자소송시스템을 이용하여 조서 말미에 정정의 취지를 부기하거나 이미 작성한 조서의 결재를 취소하고 새로운 조서를 작성·결재하는 방식(다만 관계인이 조서를 열람, 출력 또는 복제하거나 조서의 정보 등을 교부 또는 송달받은 경우에는 관계인이 정정 전 조서를 열람할 수 있도록 하여야 한다)으로 정정할 수 있다(민전예규 48조의2 3항). 예외적으로 종

이로 조서를 작성하는 경우 조서의 기재에 오·탈자가 있는 경우에는 정정하고 삽입, 삭제, 정정 등의 사유와 정정한 글자 수 또는 행을 난 외에 적은 후에 정정한 곳에 정정인을 날인한다(구체적 방법에 관하여는 ‘재판서 기타 법원의 소송서류 중 오자정정요령’ 참조). 간인은 우측 상단부에 하고, 증거목록 상호 간에는 간인하지 아니한다(조서예규 7조 6항).

신청, 그 밖의 진술은 특별한 규정이 없으면 서면 또는 말로 할 수 있고(민소 161조 1항), 다른 사람의 진술이나 증거조사결과 등을 원용하여 진술하는 방법도 실무상 관행화되어 있다. 이들을 조서에 적는 요령은 다음과 같다.

나. 서면에 의한 진술

소장·답변서에 의하여 진술하는 경우에는 “소장 진술” 등으로 적으면 되고, 준비서면 등에 의하여 진술하는 경우에는 “2000. 6. 5. 자 준비서면 진술”이라고 적으며, 준비서면 중 일부분만을 진술하는 때에는, 예컨대 “2000. 6. 5. 자 준비서면 중 제2항 진술”이라고 적어서 진술범위를 명확히 하여야 한다. 이는 어디까지나 조서에 변론상황을 요약 기재하는 양식을 말하는 것이고, 실제 변론기일에서는 구술심리의 원칙에 따라 서면에 기재된 주요 내용을 실질적으로 진술하도록 하는 것이 바람직함은 물론이다.

당사자가 자신이 제출하여 기록에 편철된 준비서면을 진술하지 아니한다고 한 때 법원사무관등은 재판사무시스템을 이용하여 전자기록뷰어의 기록목록 중 해당 서면 부분에 “부진술”이라 표시하고, 그 서면을 “문서 등의 반환/폐기”로 처리하여 기록뷰어의 보류함으로 이동시킨다(민전예규 47조 1항). 종이기록 사건에서는 그 준비서면 표지에 “부진술”이라 표시하고, 제출한 당사자 또는 대리인의 날인을 받아놓거나 재판장이 날인하여 두는 것이 실무이다.

다. 말에 의한 진술

법원사무관등이 기일에 참여한 경우에도 실제로는 기일종료 후에 조서가 작성되고 있고, 법원사무관등이 기일에 참여하지 아니하는 경우도 있으며, 또한 기일에서의 변론 등 심리는 양쪽 당사자와 법원 사이의 대화 형태로 진행되기 때문에 논리적으로 정리됨이 없이 전후 모순되는 발언이 행하여지거나 앞의 발언을 후에 정정하는 등의 경우가 허다하다.

그러나 조서의 정리기재는 당사자들이 의도한 바를 정확히 파악하여 그에 어긋남이 없도록 하여야 한다. 따라서 심리경과에 따라 주장과 진술의 내용을 전체적으로 명확히 파악하고 논리적으로 정리한 다음 조서를 작성할 필요가 있는데, 기일종료 직후에 조서를 작성하면 해당 기일에 이루어진 변론의 전체내용을 명확히 파악하기 쉽다.

주장·진술의 전후가 특별히 법률적으로 문제 되지 아니하는 한 변론의 내용은 그 소송상 의미가 귀속되는 바에 따라 정리하여 이해하기 쉽게 표현하여야 한다. 말에 의한 진술이 전후 모순되는 경우에는 전체적으로 보아 일의적으로 파악된 주장의 취지를 적고, 일단 행해진 진술이라 하더라도 바로 취소·정정된 경우에는 후의 진술내용에 따라 적는다. 다만 같은 기일에 일단 자백하였다가 취소한 경우에는 추후 자백취소의 효력 유무를 판단할 수 있도록 각각의 진술을 모두 적어야 할 것이다.

당사자의 소송행위, 즉 신청이나 진술의 뜻을 파악함에 의심이 있으면 일단 당사자가 발언한 내용대로 적어 재판부의 판단에 맡기는 것이 옳을 것이나, 우선 재판장의 의견을 물어 기재사항의 확정을 구하는 방법도 바람직하다. 실무상으로는 당사자의 무질서한 주장을 재판장이 설명을 하도록 하여 정리한 후 최종적으로 확인된 취지를 법원사무관등에게 말하여 주고 법원사무관등이 이를 메모하여 조서에 적을 사항을 확정하는 방법도 이용되고 있다(민소 154조 4호 전단 참조).

다만 말에 의한 진술을 구체적으로 조서에 기재하기 위해서는 상당한 시

간과 노력이 필요하므로 모든 사건의 조서를 이렇게 작성하는 데에는 현실적인 어려움이 있다. 사건의 유형이나 내용에 따라 서면에 의한 진술 중심으로 조서를 작성하면 충분한 사건과 말에 의한 진술까지 포함하는 것이 적절한 사건을 분류하여 운용의 묘를 살릴 필요가 있다. 말에 의한 진술을 조서에 포함할 필요가 있으나 진술내용의 핵심을 정리하는 것보다 기록 및 보관 자체가 중요한 경우에는 직권으로 법정녹음(민소 159조) 제도를 활용하는 방안도 고려할 수 있을 것이다. 한편 소송대리인이 선임되어 있다면 조서에 일일이 석명 및 답변 내용을 기재하는 대신, 대리인으로 하여금 차회 기일까지 석명에 대한 답변을 포함한 준비서면을 제출하게 함으로써 업무처리의 효율성을 도모할 수 있을 것이다. 증인, 감정인 등의 진술이 이해하기 어렵거나 모순되는 경우에는 해당 증인등신문 절차에서 재판장이 그 진술의 취지를 명확히 하는 질문을 하여 답변을 듣는 방법으로 자연스럽게 정리된 내용을 증인등신문조서에 반영시킬 수 있다.

라. 원용 진술

(1) 의 의

변론에서 이미 행해진 다른 사람의 진술 또는 증거조사의 결과 등과 같은 내용의 진술을 하고자 하는 당사자는 같은 내용을 반복하여 진술하는 번거로움을 피하기 위하여 이미 행하여진 다른 사람의 진술 등을 원용한다고 진술하는 경우가 많다. 이 경우 조서에 적을 때에도 같은 내용을 반복하여 적을 필요는 없고, 원용되는 대상을 명백히 표시하고 원용진술의 뜻을 적으면 된다. 원용할 수 있는 대상은 이미 진술되거나 변론에 현출된 것으로서 그 내용이 조서 또는 당사자의 제출서면 등에 적혀 있고 당해 기록에 편철되어 있는 것이어야 한다. 이러한 요건을 갖추었다면 서면에 의한 것이든 말에 의한 것이든 불문하고 변론의 내용이든 증거조사의 결과이든 상관없다.

(2) 타인 진술의 원용

(가) 보조참가인이 한 변론의 원용

보조참가인이 한 공격방어방법의 제출이나 그 밖의 소송행위(민소 76조 1항)를 당사자가 원용한 경우에는 나중에 참가불허의 재판이 확정되거나 참가신청이 취하되더라도 그 소송행위는 당사자 자신이 한 것과 같은 소송법상 효력이 있다(75조 2항). 따라서 이와 같은 원용진술이 있었을 때에는 원용의 대상이 된 사항과 원용하였다는 취지를 조서에 적어야 한다. 실무상은 조서에 직접 원용 진술을 기재하는 대신 차회 기일까지 그러한 원용의 취지를 포함하는 준비서면을 제출하도록 하는 방법도 이용되나, 해당 기일에 변론을 종결하는 경우에는 조서 기재를 누락하지 않아야 할 것이다.

[조서기재례]

① 참가인의 준비서면 기재사항을 원용할 경우

원고

보조참가인 제출의 2000. 6. 5. 자 준비서면 중 제2항 기재부분을 원용

② 참가인이 다른 기일에 진술한 것을 원용할 경우

피고

보조참가인의 2000. 6. 5. 자 제3차 변론에서의 진술 중 이 사건 채무를 변제하였다는 부분을 원용

③ 참가인이 당해 기일에 진술한 것을 원용할 경우

보조참가인

이 사건 수표는 그 발행일로부터 15일 후인 2000. 10. 20. 14 : 00경 ○○백화점에서 소매치기 당한 것이라고 진술

피고

보조참가인의 위 진술을 원용

독립당사자참가신청이 나중에 각하된 경우에 참가인이 제출하였던 증거자료는 당사자가 원용하지 않는 한 증거판단을 할 필요가 없다(대법원 1966. 3. 29. 선고 66다222 판결).

(나) 공동소송인이 한 변론의 원용

통상공동소송의 경우, 각 공동소송인과 상대방 사이에 각별로 소송관계가 존재하므로 공동소송인 중 한 사람의 또는 한 사람에 대한 소송행위는 다른 공동소송인에 대하여는 아무런 효력이 없고(민소 66조), 이른바 주장공통의 원칙은 적용되지 아니한다(대법원 1994. 5. 10. 선고 93다47196 판결). 예컨대 공동피고 중의 한 사람은 소멸시효항변을 하고 다른 한 사람은 그 주장을 하지 않은 경우, 소송결과가 달리 나올 수 있는 것이다. 그리하여 공동소송인 중 일부가 다른 공동소송인이 한 주장사실을 자기도 그와 같은 주장을 하겠다는 의미에서 원용을 하는 예가 실무에서 흔하다. 이때의 원용진술은 그 사실을 자기도 주장하겠다는 의미를 가지는 것이며 같은 주장사실을 되풀이하여 진술하는 대신 원용이라는 간략한 방법을 취하는 것이다. 원용진술의 조서기재는 보조참가인 진술의 원용기재방식에 준하여 하면 된다.

(다) 상대방이 한 변론의 원용

한쪽 당사자가 상대방의 주장사실을 자기의 주장으로 하기 위하여 상대방의 주장사실을 원용한다는 진술을 하는 경우가 있다. 예컨대 소멸시효의 항변을 주장하고 있는 피고가 원고의 주장책임에 속하는 시효중단사유에 관한 사실을 진술하는 경우처럼, 상대방이 이쪽 당사자의 주장책임에 속하는 사실을 진술한 경우에 이쪽 당사자가 원용의 진술을 행하는 예가 흔하다. 이와 같은 원용의 진술이 있으면 대부분의 경우에 재판상 자백이 되므로 원용의 대상과 원용의 진술을 변론조서에 분명히 적어야 한다(민소 154조 1호). 기재 방법은 보조참가인 진술의 원용의 경우에 준하여 보면 된다.

이와 같은 상대방의 진술(즉 자신에게 불리하고 반대편에 유리한 진술)은 원용이 있기 전까지는 임의로 철회할 수 있으므로 그 철회 후에는 소송자료에서 제거되고 원용도 불가능하다(대법원 1986. 7. 22. 선고 85다카944 판결, 대법원 2016. 6. 9. 선고 2014다64752 판결).

(3) 증거조사결과와 원용

(가) 상대방이 제출한 증거의 원용

소송의 실제에서 상대방의 신청에 의하여 한 증거조사의 결과(서증, 증인의 증언 등)가 자기에 유리하다고 판단될 경우 이를 이익으로 원용한다고 진술하는 예가 있다. 그러나 증거공통의 원칙상 일단 증거조사가 완료된 증거는 상대방의 원용이 없더라도 법원의 자유로운 판단에 따라 신청인에게 불리하게 사용될 수도 있는 것이므로(대법원 2004. 5. 14. 선고 2003다57697 판결) 이와 같이 이익으로 원용한다는 진술은 법원의 주의를 환기하는 데 불과한 것이다. 다만 판례는 상대방이 원용하지 않은 증거를 법원이 배척할 경우에는 그에 대한 판단을 표시하지 않아도 위법이 아니라고 하므로(대법원 1974. 10. 8. 선고 73다1879 판결) 그 범위 안에서 원용의 실익이 있고 따라서 이를 조서에 적는 것이 좋을 것이다.

서증에 대하여 원용이 있는 경우에는 증거목록의 인부요지란에 “성립인정, 이익으로 원용”의 방식으로 적는 것이 관례이다. 증인의 증언에 대하여는 원용의 진술을 하는 경우가 거의 없으나(상대방 신청의 증인이 상대방 당사자의 주신문에서 이쪽에 유리한 증언을 하는 경우에는 반대신문의 기회에 그 취지를 확실히 해둠으로써 족하다고 생각하기 때문인 듯하다) 만약 원용의 진술이 있을 때에는 증거목록이 아닌 변론조서의 “출석한 증인 별지조서와 같이 신문” 다음에 원용대상 증언부분을 간략히 특정하여 “피고 대리인, 증인 ○○○의 증언 중 …라는 증언 부분 이익으로 원용”이라고 적는다.

법원 밖에서 행해진 상대방 신청의 증거조사결과(감정, 사실조회의 결과 등)를 이익으로 원용하고자 할 경우에는 다음 (나)의 방식에 의하는 것이 보통이다.

(나) 기일전 또는 법원 밖 증거조사 결과의 원용

① 의 의

수소법원이 변론기일에 한 증거조사의 결과는 당연히 그 법원의 증거자료

가 되지만, 수명법관, 수탁판사 그리고 변론준비절차를 진행하는 재판장등에 의한 증거조사 또는 수소법원이 기일전 또는 법원 밖에서 한 증거조사는 그 결과가 변론에 현출되지 않으면 증거자료가 될 수 없다.

이러한 증거조사의 결과가 반드시 당사자의 원용이 있어야만 증거자료로 쓸 수 있는지에 관하여는 학설의 대립이 있다. 양쪽 당사자 모두가 증거조사 결과를 원용하지 않는다는 의사를 명백히 한 경우에도, 원래 이 경우의 원용 진술이란 증거조사 완료에 의하여 실질적으로 이미 증거자료가 된 기일전 또는 법원 밖 증거조사의 결과를 변론에 상정하기 위한 보고적 진술에 불과한 것이기 때문에, 법원이 이에 구속되지 않고 적절한 방식으로 법정에서 제시하여 의견진술의 기회를 주기만 하면 증거로 삼을 수 있다고 보는 것이 실무의 처리태도인 듯하고, 학설로서도 다수설이다. 판례는 양쪽 당사자가 원용하지 아니한 감정서를 증거로 한 것은 잘못이라고 판시한 것(대법원 1971. 3. 23. 선고 71다182, 183 판결)도 있으나, 대체로 감정 결과는 당사자가 증거로 원용하지 아니하여도 법원이 증거로 할 수 있다는 입장(대법원 1976. 6. 22. 선고 75다2227 판결, 대법원 1994. 8. 26. 선고 94누2718 판결)인 것으로 이해된다.

② 실무의 운용

실무에서는, 재판장이 법정에서 기일전 또는 법원 밖 증거조사 결과(증인 신문조서, 검증조서, 감정서, 사실조회회보서 등)를 고지하였음을 변론조서에 기재한 후 증거로 사용하고 있다. 해당 증거신청을 한 당사자가 이를 원용한다고 진술하면서 조서 기재를 희망하면 이를 변론조서에 적거나, 양쪽 당사자가 모두 원용한다는 진술을 한 때에는 그 취지를 적기도 하나, 이러한 명시적인 원용 기재가 없더라도 고지 사실이 기재되었다면 증거로 사용할 수 있다. 물론 기일 속행이 예정되어 있다면 당사자로 하여금 고지된 증거에 대하여 차회 기일까지 서면으로 의견을 제출하도록 명하는 방법도 이용할 수 있을 것이다.

재판장이 증거조사결과의 원용 여부를 묻은 사실을 변론조서에 적는 예도 있으나, 이를 생략하고 원용의 진술만을 적는 예도 흔하며 그렇게 적어도 무방하다.

[조서기재례]

① 원고 대리인
신체감정결과 원용
② 양쪽 당사자
검증 및 감정결과 각 원용
③ 피고 대리인
사실조회결과를 원용하지 않는다고 진술
④ 원고 대리인
위 사실조회결과 원용

양쪽 당사자 모두가 원용하지 않는다는 진술을 한 경우에는 재판장이 해당 증거조사의 결과를 제시하고 의견진술의 기회를 주었다는 점에 중점을 두어 다음과 같이 적는다.

[조서기재례]

재판장
○○ 작성의 사실조회회보서(감정인 ○○○ 작성의 감정서 등)가 도착하였음을 고지
양쪽 당사자
위 사실조회결과(위 감정결과 등)를 원용하지 않는다고 진술

(다) 증거보전결과의 원용

이에 대하여는 제25장(증거조사) 참조.

(라) 증거자료에 나온 요건사실의 원용

변론주의의 원칙상 소송자료인 사실주장과 증거자료인 진술은 구별이 되어, 법원은 증거조사과정에서 새로운 요건사실을 알게 되어도 당사자의 주

장이 없는 한 이를 소송자료로 채용할 수 없다. 따라서 증인이 증인신문과정에서 당사자가 아직 변론에서 주장하지 아니한 사실(예컨대 일부 변제·면제, 기한유예)을 진술한 경우에 당사자가 이를 주장사실로 원용하면 보조참가인의 진술 원용에 관한 기재방식에 준하여 변론조서에 기재한다. 앞서 본 바와 같이 이러한 경우 재판장은 당사자의 주장내용을 명확히 하기 위하여 원용한 당사자에게 주장내용을 기재한 준비서면을 제출하도록 소송지휘를 할 수도 있다.

마. 변론준비기일의 결과 및 변론결과의 진술

(1) 의 의

변론준비기일이 열린 경우에는 구술변론주의의 원칙상 그 결과를 변론에 상정해야 하고, 직접주의의 원칙상 법관이 바뀔 경우에는 변론갱신의 절차로서 종전 변론결과를 진술하여야 하며, 항소심에서는 제1심의 변론결과를 진술하여야 한다.

(2) 변론준비기일 결과의 진술

변론준비기일은 변론절차가 아니므로 변론준비기일이 종료하여 변론이 개시되면 변론준비기일의 결과를 진술하여야 한다(민소 287조 2항). 변론준비기일 결과의 진술은 당사자가 정리된 쟁점 및 증거조사 결과의 요지 등을 진술하거나, 법원이 당사자에게 해당사항을 확인하는 방식으로 할 수 있다(민소규 72조의2). 변론준비기일조서에 위와 같은 쟁점정리 및 증거조사 결과의 요지가 기재되어 있다면 그 조서에 의하여 진술할 수 있고, 당사자가 제출한 (요약)준비서면을 진술하는 방식으로도 결과를 진술할 수 있다. 이러한 결과 진술이 있으면, 변론조서에 그 취지를 적어야 한다. 다만 효율적 조서 작성 측면에서 그때까지 제출되거나 작성된 준비서면 및 조서에 기초하여 쟁점 및 증거조사 결과를 파악하는 데 별다른 어려움이 없다면, 법정에서 구술로 진술한 내용 대신 변론준비 결과를 진술하였다는 취지만을 조서에 기

재하더라도 무방할 것이다.

[조서기재례]

- ① 쟁점정리 및 증거조사 결과의 요지를 기재한 변론준비기일조서로 결과를 진술한 경우
 쌍방대리인
 변론준비기일조서에 의하여 변론준비기일 결과 진술
- ② 쟁점정리 및 증거조사 결과의 요지를 기재한 준비서면으로 결과를 진술한 경우
 원고
 2000. 6. 5. 자 준비서면으로 변론준비기일 결과 진술
- ③ 당사자에게 확인하는 방식으로 결과를 진술하는 경우
 재판장
 변론준비기일조서에 의하여 변론준비기일에 제출된 소송자료를 설명하고, 이 사건 쟁점을 원고의 점유개시 시점과 점유개시경위에 불법행위가 개재되었는지 여부에 있음과 증거조사를 통하여 위 쟁점에 관한 사실관계가 증명되어야 함을 확인하였음을 설명하고, 이에 대한 보충 또는 이의 여부를 물음
 쌍방대리인
 보충 또는 이의할 사항이 없다고 진술
- ④ 간략하게 변론준비기일 결과 진술의 취지만을 기재하는 경우
 쌍방대리인
 변론준비기일 결과 진술

변론준비기일의 결과는 양쪽 당사자가 진술하여야 하나 한쪽 당사자가 출석하지 아니한 때에는 출석한 당사자만 진술하여도 무방하다. 이 진술이 있으면 변론준비기일에서 한 모든 소송행위가 변론에서 행한 것과 같은 효과를 갖게 된다.

(3) 종전 변론결과와 진술

소송계속 중 법관이 바뀔 때에는(파기환송, 파기이송 또는 이송의 경우를 포함한다) 변론갱신의 절차를 밟아야 한다(민소 204조 2항). 종전의 변론결과에는 증거조사의 결과가 포함된다. 조서기재례는 다음과 같다.

[조서기재례]

변론갱신

양쪽 당사자

① 종전 변론결과 진술

② (파기환송 또는 파기이송된 경우) 환송전(이송전) 당심 변론결과
진술

(4) 제1심 변론결과와 진술

항소심에서는 심리를 개시할 때 당사자로 하여금 제1심 변론의 결과를 진술하게 하여야 한다(민소 407조 2항). 그러한 진술을 통해 제1심의 소송자료를 항소심의 소송자료로 포함시키게 된다(409조 참조). 제1심 변론결과와 진술 없이 항소심이 심리를 진행한 후 제1심 변론에 나타난 자료에 의하여 판결하면 위법이다. 그러나 이 진술은 단순히 보고적 의미를 가지는 데 불과하므로 당사자 각자가 자기의 변론결과를 구체적으로 재현할 필요는 없고 양쪽 당사자가 하든 한쪽 당사자가 전부를 진술하든 상관없다.

당사자가 항소심에서 소송관계를 표명하고 증거조사결과에 대하여 변론을 하였다면 그 당사자는 제1심 소송절차에서 이루어진 모든 공격방어방법과 증거조사의 결과를 원용한 것이 된다(대법원 1987. 12. 22. 선고 87다카1458 판결).

바. 진술의 철회

변론주의를 채택한 우리 민사소송법에서, 진술 또는 주장의 철회는 자유이다. 변론조서에는 당해 기일에서의 변론을 진술된 순서대로 일일이 적는 것이 아니고 그 기일이 종료되는 시점에 당사자가 유지하는 주장만을 정리하여 그 요지를 적는 것이므로, 같은 변론기일 중에 당사자가 일단 진술한 것을 철회한 경우에는 그 주장이 처음부터 없었던 것과 같이 취급하여 적지 아니하고 주장을 변경한 경우에는 변경된 주장만을 적는다. 당사자가 전후에 걸쳐 상호 모순되는 진술을 한 경우에는 종전의 진술은 나중의 진술에

의하여 정정되었다고 보는 것이 타당하다(대법원 1993. 6. 25. 선고 92다 20330 판결, 대법원 2001. 10. 12. 선고 2000다59081 판결). 전에 다른 기일에 서 하였던 주장을 후에 철회할 경우에는 그 원래의 주장과 철회의 진술 내용을 각각 별도의 변론조서에 적게 될 것이다. 일정 시점 이후에는 상대방의 동의를 받아야 효력을 가지는 소의 취하와 달리 소송상 방어방법으로서의 상계 항변은 그 수동채권의 존재가 확정되는 것을 전제로 하여 행하여지는 일종의 예비적 항변으로서 상대방의 동의 없이 이를 철회할 수 있다(대법원 2022. 2. 17. 선고 2021다275741 판결).

그러나 철회의 대상인 주장 내지 진술이 원래 재판상 자백에 해당하는 것이었을 경우라든가, 철회의 대상인 주장 내지 진술을 상대방이 원용함으로써 재판상 자백이 성립하게 된 경우에는, 자백의 취소에 관한 설명[제25장(증거조사) 참조]에서 보는 바와 같이 일정한 요건 하에서만 그 철회 또는 취소가 허용되므로(민소 288조 단서), 같은 변론기일 중에 어느 진술과 철회 또는 취소가 잇따라 행해졌더라도 반드시 원래의 진술과 철회 또는 취소의 진술을 따로 명시하여 적어야 하며, 상대방의 동의 여부가 진술된 때에는 그 진술도 모두 적어야 한다.

사. 인용·첨부

조서에는 서면, 사진, 그 밖에 법원이 적당하다고 인정한 것을 인용하고 소송기록에 붙여 이를 조서의 일부로 삼을 수 있다(민소 156조). 조서를 간편하면서도 정확하게 작성하고자 함에 그 취지가 있다. 인용대상은 도면, 사진, 계산표, 물건목록 등 제한이 없으며, 조서에는 인용목적물을 특정하여 표시하고 인용의 취지를 적어야 한다. 법정녹음시스템을 사용하여 조서의 일부로서 녹음한 녹음물도 동일하게 처리한다(159조).

인용을 위해서는 법원이 직무명령의 일환으로 법원사무관등에게 조서에 인용할 것을 명하고, 조서의 작성권자인 법원사무관등이 조서에 인용할 목

적물을 표시하여 이를 조서에 인용하는 취지를 기재하는 절차를 밟는다. 이와 같이 조서에 인용된 서면의 내용이나 목록 등은 조서에 다시 기재할 필요가 없게 된다. 다만 녹음물 또는 속기록에 대한 민사소송규칙 36조 2항의 요약조서와 3항의 요지조서는 이에 대한 예외에 해당한다.

3. 기재 내용의 생략

가. 소송이 판결에 의하지 아니하고 완결된 경우

소송이 소의 취하나 화해(화해권고결정 포함), 청구의 포기·인낙 또는 조정 성립이나 조정을 갈음하는 결정 등과 같이 판결에 의하지 아니하고 완결된 때에는, 다음 단계의 소송절차를 위하여 기일의 진행상황을 명확히 기록하고 후임 재판부나 상급심법원에 판단자료를 제공하는 조서의 통상적 기능이 필요한 경우가 별로 없게 될 것이다. 따라서 조서에 적을 사항 중에서 증거 조사에 관한 것으로서 상대적으로 그 작성에 많은 시간을 요하는 증인, 당사자 본인 및 감정인의 진술과 검증결과에 관하여는, 재판장의 허가를 받아 그 기재를 생략할 수 있다(민소 155조 1항 본문, 민소규 32조 1항). 그러나 위 경우에도 변론방식의 준수, 화해, 청구의 포기·인낙, 소의 취하와 자백에 대한 사항은 반드시 적어야 한다(민소 155조 2항). 재판장이 기재의 생략을 허가할 때에는, 생략할 대상에 관하여 판결이유에서 증거를 거시하듯이 특정함이 원칙일 것이지만, 이 제도의 취지가 불필요한 조서의 작성에 시간과 노력이 낭비되는 것을 막고자 함에 있으므로, 이러한 사항 전부에 관한 기재의 생략을 허가하는 것도 무방할 것이다.

다만 당사자의 이의가 있으면 조서의 기재를 생략할 수 없다(민소 155조 1항 단서). 그 절차를 보면, 법원사무관등은 재판장의 허가가 있는 때에는 바로 그 취지를 당사자에게 통지하여야 하고, 한쪽 당사자가 이 통지를 받은 날부터 1주일 안에 이의를 한 때에는 법원사무관등은 바로 그 사항을 적은 조서를 작성하여야 한다(민소규 32조 2항, 3항). 당사자로서는 특히 다른 사

건의 증거로 이용하고자 하는 경우에 이의를 할 필요가 있을 것이다. 통지는 상당한 방법으로 하면 되고, 통지의 취지와 방법을 소송기록에 표시하여야 한다(3조 2항). 당사자의 이의 방식에 관하여는 특별한 제한이 없으며, 조서 기재가 생략되는 전부에 관하여 이의를 하는 것은 물론이고, 특정 증인신문 조서의 생략에 관하여 이의를 하는 것도 허용된다. 실무상으로는 예컨대 화해나 조정이 성립된 때에는 바로 그 자리에서 당사자들로부터 조서의 기재를 생략하는 데 이의가 있는지 여부를 확인하여 이를 조서에 기재하여 두는 것이 편리할 것이다.

증인신문이나 당사자신문 등에 대하여 조서의 일부로 삼는 법정녹음을 한 경우에 작성된 녹취서(민소 159조, 속기·녹음예규 13조의2 1항 본문)는 조서나 조서의 일부가 되지 아니하므로 민사소송법 155조 1항 단서가 적용되지 아니하고, 소송이 판결에 의하지 아니하고 완결된 경우에는 당사자의 이의 여부와 상관없이 그 작성을 생략할 수 있다(속기·녹음예규 13조의2 1항 단서 1호).

한편 소액사건에 관해서는 화해·포기·인낙의 조서를 작성하면서 특히 필요하다고 인정하는 경우 외에는 청구의 원인을 적지 아니하는데(민소규 31조 단서), 그 필요 여부에 관하여는 소액사건심판법 11조의2 3항에서 정한 판결이유 기재 사유를 참고할 수 있다.

나. 공시송달 사건의 경우

제1심에서 피고에게 공시송달 규정(민소 194조 내지 196조)에 따라 송달을 한 사건의 경우, 법원사무관등은 재판장의 허가를 받아 서증목록에 적을 사항을 생략할 수 있다. 다만 공시송달 명령 또는 처분이 취소되거나 상소가 제기된 때에는 서증목록을 작성하여야 한다(민소규 32조 4항). 이 경우에도 당사자의 이의가 있으면 조서의 기재를 생략할 수 없는 것은 물론이다(민소 155조 1항 단서).

공시송달 사건의 경우 첫 기일에 변론이 종결되는 경우가 많고 서증의 정

리가 비교적 간단하므로 불필요한 업무를 경감하기 위한 것이다. 참여사무관등은 재판장의 허가를 얻어 제출된 서증의 개수를 확인하여 조서에 간략히 “갑 제1 내지 9호증 제출” 등의 형식으로 기재하면 족하다. 다만 공시송달 명령 또는 처분이 취소되거나 상소가 제기되면 서증목록을 작성하여야 하는데, 공시송달 사건의 특성상 인부기일, 인부요지는 적을 필요가 없을 것이므로 기록 앞부분에 미리 편철해 둔 서증목록 양식에 ‘서증번호’, ‘기일 및 장수’, ‘서증명’만 보충하여 적으면 된다. 그사이에 참여사무관등이 변경된 때에도 앞에서 본 바와 같이 “갑 제1 내지 9호증 제출” 등의 방식으로 기일의 조서에 제출된 서증의 개수에 따른 서증번호를 간략히 적은 이상, 변경된 참여사무관등이 ‘서증번호’, ‘기일 및 장수’, ‘서증명’을 보충하여 적는 것은 민사소송법 152조 1항 본문(“법원사무관등은 변론기일에 참여하여 기일마다 조서를 작성하여야 한다.”)에 위반되지 않는 것으로 보아야 한다.

제23장

조서의 작성 및 변론의 녹음 등

4. 조서작성프로그램을 이용한 조서 작성

법원사무관등은 원칙적으로 전자문서 방식으로 조서를 작성하여야 하고(민전 10조 1항, 민전예규 4조 2항), 이를 위해 조서작성프로그램을 사용한다(민전예규 69조 1항). 이때 법원사무관등은 당사자·대리인의 출석 여부, 주장·신청서면의 진술 여부, 서증인부와 증거 채택결과, 그 밖의 기일 진행결과를 조서작성 프로그램 화면의 해당란에 입력한다(81조 1항). 실시간조서작성프로그램에서 정보선택을 통하여 해당 정보를 입력하도록 구성되어 있는 메뉴에서는 반드시 그 사용방법에 따라 조서 내용이 기록되도록 하여야 하고, 조서 초고를 수정하는 방법으로 작성하여서는 아니 된다(69조 2항).

제4절 조서기재의 이의 및 정정

1. 총 설

조서는 후술하는 바와 같이, 그 형식적 기재사항에 관하여는 법정증거력이 부여되고 실질적 기재사항 역시 변론의 내용에 관한 보고문서로서 공증하는 의미를 가지므로 사실상 강한 증명력을 가지게 된다. 이러한 중요성을 가지는 조서의 작성에는 정확성 및 공정성을 확보할 절차가 마련되어야 하고, 아울러 잘못된 조서의 기재를 바로 잡을 수 있는 조치가 강구되어야 한다.

한편 화해, 청구의 포기·인낙을 기재한 조서 등은 확정판결과 동일한 효력을 가지므로, 판결의 경정에 관한 민사소송법 211조를 준용하여 조서의 경정이 인정된다(대법원 2001. 12. 4. 자 2001그112 결정, 대법원 2011. 10. 13. 자 2011그181 결정). 화해조서, 청구의 포기·인낙 조서의 경정에 관한 자세한 설명은 제30장(소송의 종료) 참조.

2. 조서의 공시와 이의

가. 조서의 공시

조서는 관계인이 신청하면 그에게 읽어주거나 보여주어야 한다(민소 157조). 여기서 관계인이란 당사자·소송대리인·보조참가인은 물론 증인·감정인 등도 그 진술 부분에 관한 한 이에 포함된다. 이 규정은 원래 조서가 기일 중에 동시에 순차적으로 작성되는 것을 전제로 하여 그 기일 도중에도 이미 진술한 부분의 기재 내용을 확인하기 위하여 조서의 낭독이나 열람을 신청할 수 있도록 한 것이다. 그러나 기일이 지난 후 조서를 작성하고 있는 실무 관례상 실제로는 조서가 작성되어 기록에 편철된 다음에야 비로소 그 신청이 가능하게 된다. 그 결과, 실무상으로도 이 규정에 의한 조서낭독·열람신청권이 행사되는 예는 거의 없고, 그에 대신하여 소송기록의 열람권이

나 증명서의 교부청구권(162조)이 행사되고 있을 뿐이다.

다만 위와 같은 관계인의 조서낭독 등 청구권이 조서기재의 정확성을 담보하기 위한 제도로서 민사소송법에 규정되었음을 감안하여, 관계인이 기일 도중에 조서에 기재할 사항에 대한 확인을 구하는 경우에는 재판장이 그 기재 여부 및 내용을 확인하여 주고, 법원사무관등도 그 확인된 내용에 따라 조서를 작성함이 바람직할 것이다.

나. 조서에 대한 이의

조서열람의 결과 그 기재에 잘못이 있다고 생각하는 관계인은 그 기재에 대하여 이의를 제기할 수 있다(민소 164조). 조서의 기재에 관하여 불복이 있으면 이 규정에 의한 이의의 방법에 의하여야 하고, 법원사무관등의 처분에 대한 이의(223조)를 하거나 상고이유로 삼는 것과 같은 방법으로는 불복할 수 없다(대법원 1989. 9. 7. 자 89마694 결정, 대법원 1995. 7. 14. 선고 95누 5097 판결).

이의가 있는 경우에는 법원사무관등이 조서에 그 취지를 적어야 한다(민소 164조). 법원사무관등은 그 이의가 정당하지 않다고 인정한 때에는 이의 대상이 된 당해 조서의 끝부분에 그 이의가 제기된 연월일과 이의의 이유를 덧붙여 이의한 취지를 적고 기명날인하여야 한다. 이의가 서면에 의한 때에는 아래의 [기재례 1]과 같이 적은 후 기명날인하면 된다. 이에 반하여 그 이의가 정당하다고 인정한 때에는 이의의 취지는 적을 필요 없이 아래의 [기재례 2]와 같이 조서의 기재만을 정정하면 된다. 법원사무관등은 조서에 대한 관계인의 이의가 정당하지 않다고 보더라도 재판장이 이와 다르게 보고 그 기재의 변경을 명한 경우에는 그 명에 따라야 할 것이나 자기의 의견을 부기할 수 있다.

제23장

조서의 작성 및 변론의 녹음 등

[기재례 1]

원고

별지 이의신청서 기재와 같이 이 조서 기재에 관하여 이의.

2000. 6. 5.

법원사무관 ○○○ ㉠

재판장 판사 ○○○ ㉠

[기재례 2]

원고의 이의신청에 따라, 이 조서의 검증결과란 제○행 기재의 “○○○”
을 “xxx”으로 정정한다.

2000. 6. 5.

법원사무관 ○○○ ㉠

재판장 판사 ○○○ ㉠

재판진행 중 재판장 또는 법원사무관등이 바뀐 경우 종전 조서의 기재에 관하여 이의신청이 있는 때의 처리 방법이 문제될 수 있다. 조서작성권자인 법원사무관등이나 그 인증권자인 재판장이 바뀌었다면 조서를 정정하는 것은 부적절하다는 견해도 있다.

그러나 판결경정의 경우 민사소송법 197조가 판결을 경정할 법원을 한정하고 있지 않아 상소에 의하여 사건이 상소심에 이심된 경우에는 그 상소심도 원판결을 경정할 수 있는 것(대법원 1984. 9. 17. 자 84마522 결정)에 준하여, 조서의 기재에 계산의 잘못, 오기 등 명백한 오류가 있다면(증인신문조서에는 당사자가 증인신문을 한 것으로 적혀 있음에도 당해 변론조서의 당사자표시란에는 당사자가 불출석한 것으로 되어 있는 경우 등) 현재의 재판장이나 법원사무관등이 종전의 조서를 정정할 수 있다고 함이 정정 제도의 취지에 부합한다. 법정녹음 등 발전된 정보통신기술을 활용하여 변론방식에 관한 기재 내용의 명백한 오류를 용이하게 확인할 수 있음에도 조서정정이 불가하다면, 조서의 절대적 증명력(민소 158조)으로 인해 당사자가 피해를 입을 수 있다는 점에서도 변경된 재판부의 조서정정 권한을 긍정함이 타당하다.

3. 조서의 정정

가. 의의 및 절차

법원사무관등이 조서를 작성하여 일단 기명날인하였더라도, 재판장이 기명날인하기 전에는 조서가 확정되지 않았으므로 법원사무관등 스스로가 잘못 기재된 것을 인식한 경우에는 스스로 그 기재를 변경할 수 있다. 재판장이 날인에 앞서 조서를 검토하고 변경을 명하면 이에 따라 그 기재를 변경할 수 있음은 명백하다.

그러나 법원사무관등과 재판장의 기명날인이 있으면 조서의 작성은 완성되는 것이므로 그 이후로는 기록에 편철된 조서를 소송관계인이 열람·복사하였는지 여부에 관계없이 그 기재를 임의로 정정하는 것은 원칙적으로 허용되지 아니한다 할 것이다. 다만 조서의 기재에 계산의 잘못, 오기 등 명백한 오류가 있는 때에는 기재 내용 전체의 취지를 변경시키지 않는 범위 내에서 재판장의 허가를 얻어 그 기재의 표현을 정확하게 바로잡는 것이 가능하다. 이를 일반적으로 조서의 정정이라 부른다.

나. 정정 방법

(1) 원칙 - 전자문서 방식으로 조서를 작성한 경우

법원사무관등은 전자기록사건 해당 여부와 관계없이 원칙적으로 전자문서 방식으로 조서를 작성하여야 한다(민전 10조 1항, 민전예규 4조 2항). 전자기록 사건에서 전자문서로 작성한 조서(물론 화해·조정 조서, 청구의 포기·인낙 조서는 제외한다)의 기재에 계산의 잘못이나 오기 등의 명백한 오류가 있는 경우에는 전자소송시스템을 이용하여 정정할 수 있다(민전규 21조 1항).

정정의 방법은 기존 조서의 결재 취소 여부에 따라, ① 조서말미에 정정의 취지를 부기하는 방식(부기방식)과 ② 이미 작성한 조서의 결재를 취소하고 새로운 조서를 작성·결재하는 방식이 있다(민전예규 48조의2 3항). 다만 관계인이 조서를 열람, 출력 또는 복제하거나 조서의 정보·등본·초본을 교부 또

는 송달받은 경우에는 관계인이 정정 전 조서를 열람할 수 있도록 하여야 하므로(3항 2호), 이때에는 결재취소 전 조서와 정정한 조서가 전자기록에 함께 존재하는 방식(스탬프방식)으로 조서를 정정한다. 각 방식은 다음 표와 같이 정리할 수 있다.

[정정방식 분류표]

구분	부기방식	결재취소 방식	스탬프방식
기존 조서 결재취소 여부	불필요	필요	필요
정정할 조서의 열람·출력·복제 나 제증명 교부·송달이 이루어 진 경우의 가능 여부	가능	불가능	가능
조서 정정 후 기존 조서 존부	존재	부존재	존재
정정 전 조서의 기록 편입 여부 (기록뷰어에 남게 되는 조서)	○ (기존조서 +부기조서)	× (정정 후 조서)	△ (기록뷰어에 정정 후 조서만 보 이고, 이를 우클릭하면 정정 전 조서의 열람이 가능함)

한편 전자문서로 작성하는 조서는 전산등재 과정에서의 잘못 등으로 기록에 잘못 편입되는 경우가 발생할 수 있다. 가령 전자소송시스템 또는 정보통신망에 장애가 발생하거나 해당 재판, 소송행위 또는 기일이 전혀 존재하지 않음에도 착오로 편입되는 경우 등이 여기에 해당한다(민전예규 48조의2 1항). 이러한 경우는 효력이 없음이 분명하므로 법원사무관등은 재판장의 지시에 따라 전자소송시스템을 이용하여 잘못 편입된 조서를 기록뷰어의 보류함으로 이동하는 방법으로 해당 조서를 폐기할 수 있다(민전규 21조 1항 1호, 민전예규 48조의2 2항 전문). 이때 법원은 조서의 관계인으로부터 의견을 들어야 한다(2항 후문). 전자소송시스템에서 보류함으로 이동하는 방식을 통하여 폐기된 조서는 재판부에서만 열람이 가능하고, 폐기 이전 상태로 되돌릴 수 없다. 이러한 방식의 조서 폐기는 앞서 든 예와 같은 잘못 등으로 효력이

없음이 분명한 조서에 대해서만 한정적으로 하여야 하고, 함부로 효력 있는 조서를 폐기하지 않도록 유의하여야 한다.

위와 같은 전자문서로 작성한 조서의 정정이나 폐기에 대하여 당사자의 이의가 있는 때에는 법원이 폐기 또는 정정 전의 조서를 확인할 수 있도록 하여야 한다(민전규 21조 4항).

(2) 예외 - 종이문서 방식으로 조서를 작성한 경우

예외적으로 법원사무관등은 전자소송시스템의 장애 그 밖에 현저히 곤란하거나 부적합한 사유가 발생한 경우에는 전자문서가 아닌 형태로 조서를 작성한 후(민전 10조 1항, 민전규 19조의2 1항), 장애 사유가 해소되면 지체 없이 이를 전자문서로 변환하여 전산정보처리시스템에 등재하여야 한다(민전예규 4조의2 2항). 위와 같이 당초에 종이로 작성한 조서를 정정할 때에는 일반적인 종이문서의 정정방식에 따르는 것이 당연하고, 이에 대하여는 ‘재일 85-1 재판서 기타 법원의 소송서류 중 오자정정요령’이 상세하게 규정하고 있다.

그런데 정정대상인 조서가 이미 당사자 등에 의하여 열람이나 복사가 이루어진 경우에도 위와 같은 방법으로 조서를 정정하게 되면 그 정정일자 기재되지 않는 관계상 이미 이루어진 열람이나 발급된 조서등본의 내용과 조서가 다른 것과 같은 외관이 나타나는 문제가 있다. 따라서 이 경우에는 정정의 시기를 분명히 하는 의미에서 당사자의 이의가 있는 경우에 준하여 조서말미에 정정의 취지를 부기하는 방식으로 정정함이 상당할 것이다.

(가) 오자정정요령에 의하는 경우

‘재일 85-1 재판서 기타 법원의 소송서류 중 오자정정요령’에 의한 정정 방법은 다음과 같다.

① 누락된 문자를 삽입할 때에는 누락된 곳에 끼움표(V)를 하고, 그 끼움표 윗부분에 삽입할 문자를 기재한 후 끼움표를 한 곳에 날인하며(도장이 삽입할 문자를 덮지 않도록 한다), 그 행의 좌측 난외에 “가○자”라고 삽입한 글자의 수를 기재한다.

② 기재된 문자를 삭제할 때에는 삭제할 문자의 중앙(상하의 중앙)에 한 줄만을 가로로 긋고(글자 한 자를 지울 때도 같음) 그곳에 날인하며 그 행의 좌측 난외에 “삭○자”라고 삭제한 글자의 수를 기재한다. 다만 그 행의 문자 전체를 삭제한 때는 “삭○행”으로 기재할 수 있다. 수정액 등 약품을 사용하여 삭제하거나 면도날로 긁어서는 안 되고 반드시 지운 글자를 알아볼 수 있도록 가로줄 한 개만을 그어야 한다.

③ 기재된 문자를 정정할 때에는 위 ②의 요령으로 틀린 글자를 삭제한 다음 ①의 요령으로 끼움표(V)를 하고 그 윗부분에 새로운 글자를 기재되 날인은 끼움표가 있는 곳에 한 번만 한다. 그리고 그 행의 좌측 난외에는 “정○자”(글자 수가 같은 경우) 또는 “가○자, 삭○자”(글자 수가 다른 경우)라고 정정한 글자의 수를 기재한다.

④ 인쇄된 양식용지 중 일부 행만 기재하고 나머지 행을 사용하지 않을 때에는 그 공간인 행 전부에 ‘/’의 방향으로 대각선 한 줄을 긋고 대각선의 중앙에 날인한다(“삭○행”의 기재는 하지 아니함).

⑤ 행과 행 사이에 많은 글자를 삽입해야 할 경우에는 그 행과 행 사이에 끼움표(“<”)를 한 후 그 끼움표의 벌어진 곳(우측)에 삽입할 문자를 기입하고 그 행과 행 사이의 좌측 난외에 삽입한 글자 수를 기재한다.

(4) 부기방법에 의하는 경우

이 경우에는 다음과 같이 적는다.

[조서기재례]

이 조서의 검증결과란 제○행 기재의 “○○○”을 “xxx”으로 정정한다.

2000. 6. 5.

법원사무관 ○○○ ㉠

재판장 판사 ○○○ ㉠

제5절 조서의 증명력

1. 총 설

작성권한 있는 법원사무관등이 필수적인 형식적 기재사항을 갖추어 작성하고 재판장과 법원사무관등이 기명날인한 조서는 공문서로서 진정성립이 추정된다(민소 356조). 이와 같이 적법하게 성립된 조서는 법률상 특별한 증명력을 갖는다.

2. 변론의 방식에 관한 증명력

변론조서는 변론방식에 관한 규정이 지켜졌다는 것을 증명하는 유일한 증거방법이다(민소 158조 본문). 따라서 조서에 변론방식에 관한 사실의 기재가 없으면 다른 증거로써 그 방식의 준수를 증명할 수 없게 되는 반면 조서에 변론방식에 관한 규정을 준수한 것으로 적혀 있으면 다른 증거에 의하여 그 부적법함을 증명하는 것이 금지된다. 결국 변론방식에 관한 한 현실적으로 어떻게 변론이 행하여졌는가를 불문하고 조서의 기재와 같이 한 것으로 인정된다. 잘못된 조서 기재로 인한 당사자의 피해를 방지해야 함은 물론이고, 정보통신기술의 발전에 따라 조서 기재의 정확성이 사후적으로 검증의 대상이 되는 경우가 늘어가는 상황에서 사법불신의 소지를 줄이기 위해서도 조서 중 변론방식에 관한 부분은 특히 주의하여 정확하고 공정하게 적어야 한다. 법정녹음을 원칙으로 하고 있는 증인등신문 절차(속기·녹음예규 9조의2) 이외에, 일반 변론기일에서도 구술로 이루어진 쟁점정리 및 증거조사 결과를 정확하게 기록할 필요가 있는 경우에는 변론 녹음(민소 159조) 제도의 활용을 적극 검토할 수 있을 것이다. 또한 법정녹음 등을 통해 사후적으로 조서 기재의 오류가 확인되는 경우에도 신속하게 조서정정 절차를 이행하여야 할 것이다(조서정정 절차에 관하여는 제4절 3. 참조).

여기서 변론방식이란 법원의 구성, 법원사무관등의 참여 여부, 변론의 일시 및 장소, 당사자 또는 대리인의 출석 여부, 변론의 공개 여부(이상 민소 153조 참조), 재판의 선고 여부(154조 6호), 당사자의 호명 여부(대법원 1991. 9. 10. 선고 90누5153 판결), 판결선고의 방식(206조), 첫 변론기일에서의 변론준비기일 결과의 진술(287조 2항) 여부나 변론갱신절차에서의 종전 변론결과와 항소심에서의 제1심 변론결과와 진술 여부(204조 2항, 407조 2항) 등에 관한 사항을 의미한다.

판결문에 기재된 선고일자와 판결선고조서에 기재된 선고일자가 다른 경우에는 판결선고조서 기재의 선고일자에 판결이 선고된 것으로 본다(대법원 1972. 2. 29. 선고 71다2770 판결). 변론조서에 소송대리인 불출석이라고만 기재되어 있고 당사자 본인의 출석 여부에 대하여 아무런 기재가 없다면, 당사자의 변론기일 불출석은 증명되지 아니한다(대법원 1982. 6. 8. 선고 81다 817 판결).

부동산의 경매절차에서 매각기일의 절차가 적법하게 행하여졌는지 여부는 민사소송법 158조를 준용하여 매각기일조서의 기재만이 유일한 증명자료가 되고(대법원 1994. 8. 22. 자 94마1121 결정), 매각결정기일조서에 관해서도 이 조항이 준용된다(민집 126조 2항).

그러나 변론의 방식에 관한 사항이 기재된 유효한 조서가 없어진 때에는 다른 증거방법에 의한 증명이 허용된다(민소 158조 단서). 이 경우 직권조사 사항이 아닌 사항에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 때에는 변론방식에 관한 조서의 기재에 흠이 있더라도 이의권의 포기·상실에 의하여 그 흠이 치유되어 적법한 것으로 취급된다. 다만 유효한 조서가 분실 또는 멸실된 경우에는 장부, 기일부, 사건메모, 전산자료 등을 참고하고 당사자 등이 조서등본을 소지하는 경우에는 그 사본을 제출하도록 하여 원래의 내용대로 재작성하는 복구 조치가 선행되어야 한다(재일 2001-5 소송기록 등 분실시의 업무처리지침 참조). 조서의 분실 또는 멸실이 화재, 사변 또는 그 밖의 재난으로 인

한 소송기록의 멸실에 따른 것이라면, 6개월 내에 당사자로부터 소장, 신청서 또는 상소장의 부분 및 사건 계속을 소명할 자료를 제출받는 절차가 진행되어야 하고, 당사자가 위 기간에 절차를 밟지 않으면 소·신청·상소가 취하된 것으로 간주된다(법원재난에 기인한 민형사사건 임시조치법 2조 1호, 3조).

3. 변론의 내용에 관한 증명력

당사자의 주장 또는 자백의 내용, 다음 변론기일의 지정과 같은 재판의 내용(대법원 1969. 6. 10. 선고 69다402 판결), 증인·감정인의 진술내용, 선서 여부, 변론의 종결 여부(대법원 1991. 9. 10. 선고 90누5153 판결) 등 변론의 내용에 관한 조서기재의 증명력에 관하여는 특별한 규정이 없다. 따라서 예컨대 변론조서의 기재와 다르게 소송당사자가 진술한 것으로 인정된 사례도 있다(대법원 1997. 10. 10. 선고 97다22843 판결). 그러나 변론조서에는 법원 사무관등이 변론의 요지를 기재하고 그 조서에는 재판장이 기명날인하며 관계인은 조서의 낭독이나 열람을 신청하고 이의를 제기할 수 있도록 되어 있음에 비추어(민소 157조, 164조), 변론의 내용이 조서에 기재되어 있을 때에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 내용이 진실한 것이라고 추정하는 정도의 강한 증명력을 갖는다고 할 것이다(대법원 2000. 10. 10. 선고 2000다19526 판결, 대법원 2001. 4. 13. 선고 2001다6367 판결). 조서에 기재된 변론 내용의 의미가 명료하지 않은 경우에는 소송진행 과정에서의 당사자들의 변론 등을 종합하여 합리적인 해석을 하여야 한다(대법원 2002. 6. 28. 선고 2000다62254 판결).

제23장

조서의 작성 및 변론의 녹음 등

제6절 변론의 녹음 등

1. 총 설

가. 관련 규정의 정비와 녹음 등의 활용

민사소송법은 제정 당시부터 법원이 직권 또는 당사자의 신청에 따라 변론의 전부나 일부를 속기하거나 녹음하여 그 속기록과 녹음물을 조서의 일부로 하는 기록방법(구 민소 148조)을 마련해두었지만, 이에 관한 규정은 한동안 사문화되어 있었고 변론기록은 ‘조서’만에 의하는 것이 일반적이었다.

그러나 변론기록의 합리화나 법원 내에서의 효율적 업무처리라는 관점에서 볼 때, ‘조서’는 변론내용 전부를 그대로 기록하기 어렵고 그 작성을 위하여 적지 않은 시간과 노력이 투입된다는 점에서 일정한 한계를 드러낸다. 특히 집중심리주의 아래에서는 과거에 비하여 단기간에 많은 증거조사가 이루어지므로 조서작성의 부담은 증가하는 한편 복잡한 사건이 증가하는 추세에 따라 보다 정확하게 심리 내용을 기록하여 당사자에 대한 절차적 만족을 충족시킬 필요성이 커지게 된다. 이러한 측면에서 변론의 속기 또는 녹음은 더욱 중요한 의미를 갖게 된다.

또한 현재의 민사사건 심리방식에서는 법원사무관등의 사건관리 보조자로서의 역할이 증대되었으므로, 법원사무관등에 대하여 기일에 참여하거나 조서를 작성하는 업무를 가능한 한 경감시키기 위해서도 변론의 속기나 녹음이 필요하다.

이러한 속기·녹음의 필요성에 따라 그 활성화를 위한 법률 규정의 정비가 2002년 민사소송법 개정을 통하여 이루어졌다. 특히 2000년대 중반 이후 디지털 방식에 의한 법정녹음시스템이 구축됨에 따라 전자파일 형태의 녹음파일 자체를 조서의 일부로 삼아 재판사무시스템에서 재생·청취할 수 있게 되어 변론의 녹음에 관한 기술적 여건이 구비되었고, 이를 바탕으로 2007년

개정 민사소송규칙에 녹음파일을 활용한 조서 기재에 관한 규정도 추가로 정비되었다.

그리고 2011년 전자소송의 시행 및 확산 이후 ‘녹음’이 변론기록의 합리화 수단으로 더욱 주목을 받게 되자, 2012. 7.부터는 법정녹음에 의한 변론기록화 방안이 시범적으로 실시되었고, 그 과정에서 나타난 녹음에 의한 변론기록방법의 단점을 보완하고 장점을 더욱 살리기 위한 민사소송규칙 등의 추가적 규정 정비와 법정녹음시스템의 정비·개선을 거쳐, 2015. 1. 1.부터는 법원 실무에서 녹음에 의한 변론기록화 방안이 본격적으로 활용되기 시작하였다.

나. 녹음 등의 형태

민사재판절차에서의 녹음(속기)은, ① 직권·신청에 따라 속기록 또는 녹음테이프를 조서의 일부로 삼는 녹음(속기)(민소 159조 1항, 2항, 283조 2항), ② 법원사무관등의 참여를 갈음하는 녹음(속기)으로서, 기일이 끝난 후 재판장의 설명에 따라 조서를 작성하는 경우(②-1, 152조 1항 단서, 3항, 283조 2항)와 녹음테이프(속기록)가 조서의 일부가 되는 경우(②-2, 152조 1항 단서, 민소규 36조 1항), ③ 조서 작성의 편의와 조서 기재 내용의 정확성을 보장하기 위한 녹음(속기)(속기·녹음예규 2조 3호 및 4장)이 있다. 이러한 3가지 유형에 관한 녹음(속기)의 세부절차는 재일 2004-3 변론의 속기·녹음에 관한 업무처리요령에서 규정하고 있는데, 이를 정리하면 다음과 같다.

[녹음 등 유형분류표]

구분	근거규정	조서작성 방식	예규 규정
① 직권·신청에 의한 녹음·속기	민소 159조(변론기일) 민소 283조 2항(변론준비기일)	녹음테이프와 속기록을 조서의 일부로 삼음(민소 159조 2항)	2조 2호, 제3장
② 법원사무관등의 참여를 갈음하는 녹음·속기	민소 152조(변론기일) 민소 283조 2항(변론준비기일)	②-1 기일 끝난 후 재판장의 설명에 따라 작성(민소 152조 3항)	2조 1호, 제2장
		②-2 녹음테이프 또는 속기록을 조서의 일부로 삼을 수 있음(민소 규 36조 1항)	2조 2호, 제3장
③ 조서 작성 편의를 위한 녹음·속기	없음	통상적인 조서작성 방식과 같음	2조 3호, 제4장

위 각 유형 중 녹음테이프나 속기록이 조서의 일부가 되는 경우(위 유형분류표 중 ①, ②-2의 경우)에는 그것이 바로 소송기록의 일부로서 민사소송법 162조에 의한 소송기록 열람·복사신청의 대상이 되므로, 변론의 속기·녹음에 관한 업무처리요령은 아래 2항에서 보는 바와 같이 그 보관방법 등을 상세히 규정하고 있다.

또한 이와 같이 녹음테이프나 속기록이 조서의 일부가 되는 유형에서 녹화테이프, 컴퓨터용 자기디스크·광디스크, 그 밖에 이와 비슷한 방법으로 음성이나 영상을 녹음 또는 녹화하여 재생할 수 있는 매체를 이용하여 변론의 전부나 일부를 녹음 또는 녹화하는 때에도 변론의 속기와 녹음에 관한 민사소송규칙 33조 내지 36조, 민사소송법 159조의 규정이 준용된다(민소 규 37조 1항, 속기·녹음예규 15조 1항). 이러한 새로운 매체가 녹음이나 속기와 비교하여 그 정확성에서 뒤지지 않기 때문이다. 나머지 유형에서의 녹음도 그와 같은 방식이 활용될 수 있음은 물론이다. 이에 따라 변론의 속기·녹음에 관한 업무처리요령은 녹음내용이 저장된 녹음테이프, 전자파일 등을 ‘녹음물’로 통칭하고 있다(2조 1호 참조. 이하의 설명에서도 특별한 사정이 없는 한 ‘녹음물’로 통칭한다).

한편 속기를 하는 경우에 속기자는 각급 법원에 소속된 속기사 또는 재판

장이 인정하는 속기능력 보유자 중에서 선정하여야 한다(속기·녹음예규 3조 1항). 각급 법원의 장은 속기자로 하여금 속기업무의 원활한 수행을 위하여 직무교육을 받도록 하여야 하고, 이러한 직무교육에는 소송절차의 개요 및 법률용어, 관계 법령 및 변론의 속기·녹음에 관한 업무처리요령에서 정한 속기·녹음의 절차에 관한 사항이 포함되어야 한다(2항).

다만 실무에서는 당사자가 속기를 특별히 신청하는 경우가 아닌 한 녹음에 의한 변론기록을 하는 경우가 일반적이므로, 이하에서는 녹음을 위주로 설명하면서 필요한 경우에 속기에 관한 내용을 언급하기로 한다.

2. 조서의 일부로 삼을 수 있는 녹음 등

녹음물 또는 속기록이 조서의 일부가 되는 경우로는 직권 또는 당사자의 신청으로 변론(준비)기일에 녹음·속기가 이루어지는 경우(민소 159조 1항, 2항, 283조 2항, 민소규 34조, 위 녹음 등 유형분류표 중 ①의 경우)와 법원사무관 등이 변론(준비)기일에 참여하는 것을 갈음하여 녹음·속기가 이루어진 후 그 조서를 작성할 때에 재판장의 허가를 받아 녹음물 등을 조서의 일부로 삼는 경우(민소 152조 1항, 3항, 283조 2항, 민소규 36조 1항, 위 유형분류표 중 ②-2의 경우)의 두 가지 유형이 있다. 이하의 설명은 전자(위 유형분류표 중 ①의 경우)의 경우에 관한 것이나, 후자(위 유형분류표 중 ②-2의 경우)의 경우에 관한 구체적인 절차도 이에 준한다.

가. 녹음 등 실시의 명령

법원은 필요하다고 인정하는 경우에는 직권으로 변론의 전부 또는 일부를 녹음하거나 속기하도록 명할 수 있고, 당사자가 신청하면 특별한 사유가 없는 한 이를 명하여야 한다(민소 159조 1항). 이 규정에 의한 녹음·속기의 경우 그 녹음물이나 속기록은 조서의 일부가 된다(2항). 이는 변론준비기일에 관하여 준용되고(283조 2항), 법원·수명법관 또는 수탁판사의 신문 또는 심

문과 증거조사에도 준용된다(160조, 민소규 37조 2항, 속기·녹음예규 15조 2항).

(1) 녹음이 필요하다고 인정하는 경우(직권 녹음)

현행 민사소송법 159조 1항은 법원이 직권으로 녹음실시를 명하는 것을 원칙적인 모습으로 규정하고 있다. 앞의 총설 부분에서 설명한 바와 같이 녹음에 의한 변론기록방법을 활성화하기 위하여 위와 같은 규정을 둔 것이므로, 법원은 그 취지를 감안하여 변론에 대한 직권 녹음의 필요성을 폭넓게 인정하여야 할 것이다. 이에 따라 구술로 이루어진 쟁점정리 및 증거조사 결과를 정확하게 기록할 필요가 있는 경우에는 일반 변론기일에서도 직권 녹음 실시를 적극 검토할 수 있을 것이다.

특히 증인신문절차나 당사자신문절차는 증인 등 관계인의 진술을 ‘말한 그대로’ 생생하게 기록하는 것이 변경된 재판부나 상급심 재판부의 심증형성에 더 도움이 되고, 조서작성을 위한 진술의 요지를 정리하는 과정에서 나타나는 일부 진술의 기재 생략이나 압축된 표현 등에 대한 당사자의 이의나 오해의 소지를 없앨 수 있으며, 법원사무관등의 조서작성에 대한 부담을 크게 덜 수 있다는 점에서 녹음이 필요한 대표적인 경우라 할 수 있다.

이러한 이유에서 법원은 법정녹음시스템이 정비·개선되어 법정녹음이 본격적으로 실시된 2015년부터 변론의 속기·녹음에 관한 업무처리요령 9조 의2에 따라 변론 중 증인신문절차 또는 당사자 본인신문절차를 민사소송법 159조 1항 전단에 따라 녹음이 필요한 경우에 해당한다고 보아 원칙적으로 그 전부에 대한 녹음실시를 명하고 있다. 이 경우 증인신문절차나 당사자신문절차가 열린 변론기일의 조서 중 변론요지란에 다음과 같이 기재한다.

[조서기재례]

재판장

민사소송법 제159조 제1항의 규정에 따라 증인의 증언내용을 녹음할 것을 명하고 당사자에게 이를 고지, 별지 조서와 같이 증인신문

다만 ㉠ 법정녹음시스템에 장애가 발생하는 등 녹음이 불가능하고, 녹음이 가능할 때까지 변론을 진행하지 아니하면 재판절차가 현저히 지연될 우려가 있는 경우, ㉡ 당사자 중 일방이 녹음에 명시적으로 동의하지 아니한다는 의사를 표시하면서 녹음으로 인해 재판에 현저한 지장이 초래되거나 당사자 또는 제3자의 권리가 부당히 침해될 우려가 있음을 소명한 경우, ㉢ 그 밖에 위 ㉠ 또는 ㉡ 중 어느 하나에 준하는 특별한 사정이 있는 경우에는, 증인신문절차나 당사자신문절차라 할지라도 녹음이 필요한 경우에 해당한다고 보지 않는다(속기·녹음예규 9조의2 단서 각 호). 가령 증인신문사항 중에 당사자나 증인 등 제3자의 사생활이나 명예와 관련된 내용이 포함되어 있는 경우에 당사자 일방이 상대방 당사자 측에 의한 법정녹음물의 외부공표 가능성과 이로 인한 당사자 등의 권리침해 가능성에 관한 소명자료를 제출하면서 녹음에 명시적으로 동의하지 않는다면, 증인신문절차에 대한 녹음의 필요성이 인정되기 어려울 것이다. 증인에게 언어장애가 있고 수화통역인에 의하여 증언이 통역되는 경우도 위와 같은 경우에 준하는 특별한 사정이 있다고 할 것이다. 이러한 경우에는 녹음실시를 명하지 않고, 종전과 같이 증인신문조서나 당사자신문조서를 작성한다.

법원이 필요하다고 인정하는 경우에는 속기를 명하는 방식으로 증인신문절차나 당사자신문절차를 기록할 수도 있다. 증인신문을 속기하기로 결정한 경우 변론조서의 ‘형식적 기재사항’란의 법원사무관 성명란 아래 난에 “속기자 ○○○”라고 기재하고, 변론조서의 변론요지란에 다음과 같이 기재한다(속기·녹음예규 13조 1항 1호, 2호).

[조서기재례]

재판장

민사소송법 제159조 제1항의 규정에 따라 속기자에게 증인의 증언내용을 속기할 것을 명하고 당사자에게 이를 고지, 별지조서와 같이 증인신문

(2) 녹음 등의 신청이 있는 경우(신청 녹음)

(가) 신청의 시기와 비용

변론 또는 증언 등의 녹음신청은 변론(준비)기일을 열기 전까지 말 또는 서면으로 하여야 한다(민소규 33조, 71조 2항, 속기·녹음예규 9조 1항 전문). 법정녹음의 준비와 기일의 원만한 진행을 위하여 위와 같은 신청 시기에 관한 규정을 두었다. 다만 기일 진행 중이라도 법원은 필요하다고 인정하는 경우에 그 시점 이후부터 녹음을 할 수 있으므로, 당사자가 기일을 연 다음에 녹음을 신청한 때에는 이를 직권발동 촉구의 의미로 파악하여 법원이 녹음의 필요성을 검토할 수 있다. 따라서 당사자가 기일을 연 다음에 녹음을 신청한 것이 방식의 위반에 해당한다는 이유로 녹음의 필요성에 대한 실질적인 검토 없이 일률적으로 녹음신청을 받아들이지 아니하는 것은 바람직하다고 보기 어렵다.

녹음을 신청하는 사람은 특별한 사정이 없는 한 녹음의 실시를 위한 별도의 비용을 미리 내지 아니한다(속기·녹음예규 9조 2항). 다만 재판장은 녹음의 실시를 위하여 별도의 비용이 필요한 특별한 사정이 있다고 인정하는 경우에는 민사소송규칙 33조 1항의 규정에 따라 녹음에 필요한 비용의 예납을 명할 수 있다(속기·녹음예규 9조 3항). 이 경우 법원사무관등은 ‘법원보관금취급규칙의 시행에 따른 업무처리지침’에 따라 업무를 처리한다.

당사자가 녹음이 아닌 속기를 신청한 경우에도 그 시기와 비용에 관해서는 위와 같다(민소규 33조, 71조 2항, 속기·녹음예규 9조).

(나) 녹음 등의 실시에 관한 재판

민사소송법 159조 1항 후단에 따르면, 당사자가 녹음(속기)을 신청하면 법원은 특별한 사유가 없는 한 이를 명하여야 한다. 신청에 따라 녹음을 명하는 경우 변론(준비기일)조서의 변론요지란에 다음과 같이 기재한다.

[조서기재례]

① 변론의 전부에 대한 녹음을 명하는 경우

재판장

원고의 신청이 있으므로 민사소송법 제159조 제1항에 따라 변론의 전부를 녹음할 것을 명하고 당사자에게 이를 고지

② 변론의 일부에 대한 녹음을 명하는 경우

재판장

피고의 신청이 있으므로 민사소송법 제159조 제1항에 따라 이 사건 토지의 소유권이전등기청구 부분에 관한 원고의 변론 부분에 대하여 녹음할 것을 명하고, 당사자에게 이를 고지

변론의 속기·녹음에 관한 업무처리요령 10조 2항 각 호는 위 민사소송법 규정에서 정한 ‘특별한 사유’에 해당하는 경우를 구체화하고 있는데, 이에 따르면 ㉠ 속기자가 없거나 법정녹음시스템에 장애가 발생하는 등 속기 또는 녹음이 불가능하고, 속기 또는 녹음이 가능할 때까지 변론을 진행하지 아니하면 재판절차가 현저히 지연될 우려가 있는 경우, ㉡ 속기장비나 법정녹음시스템이 설치되지 아니한 준비절차실 등에서 진행되는 절차에 관하여 상대방이 속기 또는 녹음에 명시적으로 동의하지 아니한 경우, ㉢ 상대방이 속기 또는 녹음에 명시적으로 동의하지 아니한다는 의사를 표시하면서 속기 또는 녹음으로 인해 재판에 현저한 지장이 초래되거나 상대방 또는 제3자의 권리가 부당히 침해될 우려가 있음을 소명한 경우, ㉣ 그 밖에 ㉠ 내지 ㉢의 어느 하나에 준하는 특별한 사정이 있는 경우에는, 당사자의 신청이 있더라도 재판장이 녹음(속기)을 명하지 아니할 수 있다. 이러한 사유는 증인신문절차나 당사자신문절차 이외의 변론절차나 변론준비절차에 관해서만 적용된다. 증인신문절차나 당사자신문절차는 당사자의 신청 유무와 상관없이 녹음이 필요하다고 보아 직권으로 녹음하여야 할 경우에 해당하기 때문이다.

재판장은 녹음이 신청된 경우에 위와 같은 특별한 사유의 존부 등을 확인하기 위하여 상대방에게 녹음 등의 실시에 관한 의견을 들 수 있다(속기·녹음예규 9조 1항 후문).

위 ㉠부터 ㉢까지 중 어느 하나에 해당하는 사유가 있다면, 재판장은 변론(준비)기일에 그 취지를 고지하여야 하고, 법원사무관등은 그 고지내용을 조서에 기재하여야 한다(속기·녹음예규 10조 2항 후문). 재판장이 당사자의 신청이 있음에도 녹음을 하지 아니한다는 취지를 고지할 때에는, 녹음을 하지 아니하는 특별한 사유의 요지도 함께 고지함이 바람직하다. 그 기재례는 다음과 같다.

[조서기재례]

재판장

변론의 속기·녹음에 관한 업무처리요령 제10조 제2항 제3호에 해당함을 이유로 원고의 녹음신청을 기각한다는 취지를 고지

한편 증인신문절차나 당사자신문절차의 경우에도 녹음시스템의 장애 및 절차의 현저한 지연 우려 사유, 당사자 중 일방의 녹음반대 및 권리침해 우려의 소명 사유, 그 밖에 이에 준하는 사유가 있는 때에는 녹음이 필요한 경우로 보지 아니한다는 점(속기·녹음예규 9조의2 단서 각 호)을 앞서 설명한 바 있는데, 증인신문절차나 당사자신문절차에 대한 녹음을 당사자 일방이 신청하였으나 위와 같은 사유로 녹음을 하지 않는 경우에도 재판장은 그 취지(사유 포함)를 고지하고, 법원사무관등이 그 고지내용을 조서에 기재함이 좋을 것이다.

당사자의 녹음(속기) 신청을 기각하는 취지의 재판은 소송절차 중의 재판으로서, 이에 대하여 독립하여 불복할 수는 없다.

(3) 녹음 등의 필요성이 없어진 경우의 처리

재판장은 녹음(속기)을 명한 후 소송관계인의 불출석 등으로 녹음(속기)의 필요성이 없어진 경우 그 명령을 취소할 수 있다. 이 경우 취소 전까지 작성된 녹음물(속기록)은 조서의 작성이 완료되면 폐기한다(속기·녹음예규 10조 3항).

나. 녹음 실시와 관련한 유의사항

재판장은 직권 또는 당사자의 신청에 따라 조서의 일부가 되는 녹음을 하기로 한 경우에 그 변론(준비)기일을 열기 전에 미리 법원사무관등에게 녹음시스템 등의 점검 및 준비 등을 지시함이 바람직하다. 증인신문절차나 당사자신문절차는 원칙적으로 녹음이 필요하다고 보므로, 법원사무관등은 별도의 지시가 없더라도 기일을 열기 전에 미리 법정녹음을 위한 점검과 준비 등의 조치를 취할 필요가 있다.

기일 전에 법정녹음시스템의 정상 작동을 점검, 확인하였더라도, 기일 중에 시스템 장애가 생기는 경우가 발생할 수 있으므로 별도의 휴대용녹음장치를 준비하여 법정에 비치하는 것이 좋다.

재판장은 녹음의 실시를 명할 때, 당사자나 증인 등 소송관계인에게 진술 내용이 녹음물에 정확히 기록되도록 법정에 설치된 마이크에 근접하여 또박 또박 발음하도록 주의를 환기시킬 필요가 있다. 당사자석을 벗어나 변론하는 경우에는 법정에 비치된 이동식 마이크나 가까운 위치에 있는 고정식 마이크를 사용하도록 한다.

변론이나 신문을 하면서 소송기록이나 그 밖의 문서, 사진, 물건 등을 제시하는 때에는 “이것”, “그것” 등의 지시대명사로 칭하지 말고 그 서증표목이나 명칭 등으로 지칭하도록 하고, 몸짓 등의 행태로 표현을 하는 경우에는 그 행태의 의미를 말로써 설명하도록 하여야, 녹음물이 소송기록으로서의 기능을 다할 수 있음을 재판장이나 법원사무관등뿐 아니라 당사자, 대리인 등 소송관계인 모두가 유의하여야 한다.

다. 녹음 등의 방식 및 보관

(1) 녹음의 경우

녹음물은 소송기록과 함께 보관하여야 한다(민소규 34조 1항). 실무상 녹음을 할 때에는 사건마다 별도로 법정녹음시스템을 이용하여 녹음하고, 그 결

과 생성되는 전자파일에는 검색이 가능하도록 고유번호를 부여하여 법정녹음시스템의 서버나 이에 준하는 서버에 보관한다(속기·녹음예규 11조 1항 본문). 영상재판을 마친 후의 녹음물 보관에 관하여도 변론의 속기·녹음에 관한 업무처리요령을 준용하므로(영상재판예규 26조), 영상재판 프로그램에서 자체적인 녹음 또는 녹화 기능을 제공하더라도 이와 별도의 법정녹음시스템을 이용하여 녹음한다.

법정녹음시스템을 이용할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우에는 휴대형 녹음장치 등 다른 녹음저장매체를 사용할 수 있는데, 이 경우의 녹음물은 고유번호를 부여하는 등 검색할 수 있는 조치를 취하여 법정녹음시스템의 서버나 이에 준하는 서버에 보관한다(속기·녹음예규 11조 2항 전문). 만일 법정녹음시스템의 서버나 이에 준하는 서버에 보관할 수 없는 경우에는 컴퓨터용 디스크, 그 밖에 이와 유사한 정보저장매체에 복제한 다음, 저장매체의 표면에 사건번호, 녹음일시 및 녹음내용의 개요(예: “증인 ○○○의 증언”)를 표시하여, 전자기록 사건에서는 저장매체를 별도의 기록으로 보관하고 전자소송시스템에 그 사실을 입력하는 방식으로, 전자기록이 아닌 사건에서는 저장매체를 봉투에 넣어 붙인 후 소송기록에 가철한 다음 녹음물이 폐기될 때까지 “녹음물 있음”이라고 붉은 글씨로 기재한 부전지를 소송기록 표지 중앙 하단에 견고하게 붙이는 방식으로 보관한다(2항 후문 각 호).

(2) 속기의 경우

속기자는 속기를 마친 경우 지체 없이 속기록[전산양식 A1685, A1685-1]을 작성하고 기명날인한 다음 법원사무관등에게 제출하여야 하고, 법원사무관등은 속기자가 제출한 속기록의 내용을 검토하여 표현의 오류가 있으면 속기자로 하여금 이를 바로잡도록 한 다음 속기록을 그 기일의 변론(준비기일)조서(이하 ‘기본조서’라 한다) 또는 증인신문조서·당사자신문조서 등의 뒤에 첨부하여 기록과 함께 보관하여야 한다. 법원사무관등은 속기록을 조서 뒤에 첨부한 이후에 속기록의 오류를 발견한 때에는 조서정정절차에 따라

기재를 정정하여야 한다(민소규 34조 1항, 속기·녹음예규 11조 4항, 5항, 6항).

라. 녹음물 등의 열람·복사

민사소송법 159조의 규정에 의한 녹음(속기)의 경우 그 녹음물(속기록)은 조서의 일부가 되므로(민소 159조 2항), 당사자 등의 소송기록 열람권의 한 형태로서(162조 참조) 당사자나 이해관계를 소명한 제3자는 법원사무관등에게 그가 보관하고 있는 녹음물의 청취·시청·복제 또는 속기록의 열람·복사를 신청할 수 있다(민소규 34조 2항). 이때 신청은 녹음물 등 열람·복사 신청서[전산양식 A2206]를 이용한다(속기·녹음예규 12조 1항). 이 신청은 소송기록 열람권을 행사하는 것이므로 이를 거부할 수 없다.

열람 등의 신청인은 '재판기록 열람·복사 규칙'에 따른 수수료를 납부하여야 한다(민소 162조 5항, 속기·녹음예규 12조 2항).

마. 기본조서의 작성

조서의 일부로 삼기 위하여 변론의 전부 또는 일부에 대한 녹음(속기)이 행해진 경우, 해당 녹음물(속기록)은 별다른 조치 없이 그대로 조서의 일부가 된다. 다만 이 경우에도 법원사무관등은 기본조서를 작성하고 녹음(속기)을 실시하는 취지의 결정 및 그 고지에 관한 사항과 녹음물(속기록)을 인용한다는 취지를 기재하여야 하고, 속기를 한 경우에는 속기자의 성명도 기재하여야 한다(속기·녹음예규 13조 1항). 이 경우에는 그 녹음물(속기록)을 폐기할 수 없다.

변론의 전부를 녹음(속기)하여 녹음물(속기록)을 조서의 일부로 삼는 경우의 기본조서의 양식은 [전산양식 A1680(변론의 전부 속기), A1680-1(변론의 전부 속기, 참여 불출석), A1681(변론의 전부 녹음), A1681-1(변론의 전부 녹음, 참여 불출석)]과 같고, 변론의 일부를 녹음(속기)하여 녹음물(속기록)을 조서의 일부로 삼는 경우의 기본조서의 양식은 [전산양식 A1682]와 같으며, 증인신

문조서의 양식은 [전산양식 A1683]과 같다(속기·녹음예규 13조 2항, 3항).

[전산양식 A1681] 기본조서(변론의 전부 녹음)

○ ○ 법 원		
변 론 조 서		
차		
사 건 20 가		
재판장 판사	기 일 :	20 . . . :
판 사	장 소 :	제○호 법정
판 사	공개 여부 :	공 개
법원사무관	고 지 된	
	선고기일 :	20 . . . :
사건과 당사자의 이름을 부름		
원 고 대리인 변호사 ○○○		출석
피 고 대리인 변호사 ○○○		출석
증인 ○○○		출석
재판장 판사		
법원사무관에게 민사소송법 제159조 제1항의 규정에 따라 변론의 전부를		
녹음할 것을 명하고 당사자에게 이를 고지		
변론의 내용, 증인신문 내용은 법정녹음시스템의 녹음파일(고유번호: 0000)과		
같음		
증거관계 별지와 같음(피고 증인등)		
변론종결		
	법원사무관	○○○
	재판장 판사	○○○
민소 159①,②		

[전산양식 A1681-1] 기본조서(변론의 전부 녹음, 참여불출석)

○ ○ 법 원

변 론 조 서

차

사 건 20 가

재판장 판사
판 사
판 사기 일 : 20 . . . :
장 소 : 제○호 법정
공개 여부 : 공 개
고 지 된
선고기일 : 20 . . . :

사건과 당사자의 이름을 부름

원 고 대리인 변호사 ○○○
피 고 대리인 변호사 ○○○
증인 ○○○출석
출석
출석

재판장 판사

민사소송법 제152조 제1항 단서의 규정에 따라 변론의 전부를 녹음한다는
사실을 당사자에게 고지변론의 내용, 증인신문 내용은 법정녹음시스템의 녹음파일(고유번호: 0000)과 같음
증거관계 별지와 같음(피고 증인등)

변론종결

이 조서는 민사소송법 제152조 제3항의 규정에 따라 기일이 끝난 다음 재판장의
설명에 따라 작성하였음법원사무관 ○○○
재판장 판사 ○○○

민소 152①,③

제23장

조서의 작성 및 변론의 녹음 등

이 경우 조서기재례는 다음과 같다.

[조서기재례]

① 법정녹음시스템에 의한 녹음파일을 조서의 일부로 삼는 경우 (증인신문조서의 진술요지란) 증인 ○○○에 대한 신문내용은 법정녹음시스템의 녹음파일(고유번호: 171117123456)과 같다. ② 속기록의 전부를 조서에 인용한 경우 (변론조서의 요지란) 속기자 ○○○ 작성의 속기록과 같다. (증인신문조서의 진술요지란) 증인에 대한 신문내용은 별첨 속기자 ○○○ 작성의 속기록과 같다. ③ 속기록의 일부를 조서에 인용한 경우 (당해 조서의 인용부분을 기재할 장소에) 속기자 ○○○ 작성의 속기록 중 제○면 제○행부터 제○면 제○행까지의 기재와 같다.
--

바. 녹취서 등에 의한 기록 보완

녹음은 변론을 정확하고 편리하게 기록한다는 측면에서 장점이 크지만, 재판부 변경 후의 후임재판부나 상소심재판부, 녹음 후에서야 사건에 관여한 관계인, 대리인 등이 종전 변론의 요지를 파악하는 데에는 다소간 불편이 따르는 단점이 있다. 이러한 단점을 극복하여 짧은 시간에 종전 변론결과의 요지를 파악하기 위해서는 아무래도 활자화된 보완적 기록방법이 있는 것이 도움이 되는데, 민사소송법과 민사소송규칙은 녹음에 대한 보완적 기록방법으로서 녹취서, 요약조서, 요지조서 등을 활용할 수 있는 근거를 마련해 두었다.

(1) 녹취서

가) 녹취서를 작성하는 경우

재판장이 필요하다고 인정하는 때에는 법원사무관등 또는 속기자에게 녹음물에 녹음된 내용에 대하여 녹취서를 작성할 것을 명할 수 있다(민소규 35

조 1항).

특히 증인신문절차나 당사자신문절차처럼 당사자·증인 등 소송관계인의 진술 전부와 그 진술의 맥락이 소송자료로 활용될 여지가 큰 경우에는 녹음물과 더불어 그 녹음된 내용에 대한 활자화된 기록의 필요성이 더욱 커진다고 말할 수 있다. 따라서 녹음이 필요하다고 인정되어 증인신문절차나 당사자신문절차에서 녹음하는 경우에는 재판장이 속기자에 대하여 녹음물에 대한 녹취서의 작성을 명할 필요가 있다(속기·녹음예규 13조의2 1항 본문). 이러한 녹취서 작성 명령은 법원 내부의 사무처리에 관한 것이므로 당사자에게 고지할 필요가 없고, 재판장이 일정한 범위를 정하여 포괄적으로도 명할 수 있다.

그러나 증인신문절차나 당사자신문절차에 대한 녹음이 실시되었더라도, ㉠ 해당 소송이 판결에 의하지 아니하고 완결된 경우, ㉡ 증인신문 또는 당사자신문의 주신문절차가 진행되고 그 신문사항이 기록에 편철되었지만 반대신문절차는 진행되지 않은 경우(가령 공시송달 사건에서 원고만 출석한 상태로 신문절차가 진행되고 그 신문사항이 기록에 편철된 경우), ㉢ 소액사건으로서 속기자의 참석 없이 증인신문 또는 당사자신문의 절차가 진행된 경우에는 사후적 기록파악의 불편이 발생하지 않거나 속기자로 하여금 녹취서를 작성하도록 하기에 적당하지 아니하므로 녹취서의 작성을 명할 필요가 없는 경우로 본다(속기·녹음예규 13조의2 1항 단서 각 호). 위 사유 중 ㉡, ㉢에 해당하는 경우에는 증인신문조서나 당사자신문조서에 해당 사유가 있다는 취지를 기재한다(5항).

증인신문절차나 당사자신문절차가 아니더라도, 재판장은 필요하다고 인정하는 때에는 소송기록을 상소심법원에 송부하기 전까지 언제라도 속기자에 대하여 민사소송법 159조(민소규 36조 1항의 경우를 포함한다)에 따라 조서의 일부로 삼는 녹음물의 전부 또는 일부에 대한 녹취서의 작성을 명할 수 있다(속기·녹음예규 13조의2 2항). 가령 변론절차나 변론준비절차에 대한 녹음

제23장

조서의
작성
및
변론의
녹음
등

이 실시되었고 이에 대하여 상소심이나 변경 후 재판부 등을 위한 보완적 기록방법이 필요하지만, 요약조서가 작성되지 않았고, 사후적으로 통상의 방식에 따른 별도의 요지조서를 작성하는 것보다는 녹취서를 작성하는 것이 더 합리적이라면 재판장이 녹취서를 작성하도록 명하는 것이 바람직할 것이다.

(나) 작성방법

재판장이 속기자에게 녹음물의 전부 또는 일부에 대한 녹취서 작성을 명한 경우, 속기자는 지체 없이 녹취서를 작성하고, 여기에 기명날인 또는 사법전자서명을 한 다음 해당 녹취서를 법원사무관등에게 제출하여야 한다(속기·녹음예규 13조의2 3항). 녹취서는 속기록 작성에 준하여 소송관계인의 진술을 그대로 기재하거나 진술의 주요한 부분만을 정리하여 기재하는 방식으로 작성할 수 있다(4항 전문, 11조 3항). 증인등신문 절차가 아니라 일반 변론 절차나 변론준비절차의 녹음물에 대한 녹취서를 작성하는 때에는 화해, 청구의 포기·인낙, 소의 취하와 자백(민소 154조 1호), 서면으로 작성되지 아니한 재판(5호) 등 특히 법적 효력이 발생하는 진술을 누락하지 않도록 유의할 필요가 있다.

속기자는 속기를 할 때와는 달리, 녹취서를 작성하기 위하여 반드시 기일에 참석할 필요가 없다. 다만 기일에 참석하여 기본적인 진술내용을 속기, 녹음한 다음 녹음물을 들으며 녹취서를 작성하는 것이 보다 효율적이라면, 속기자가 미리 재판장과 협의하여 녹음이 실시되는 해당 절차에 참석하여 녹취를 위한 준비작업을 할 수 있다. 이 경우에는 조서의 형식적 기재사항으로 속기자의 이름을 적지 아니한다.

법원사무관등은 속기자로부터 녹취서를 제출받으면 그 녹취서의 내용을 검토하여 표현의 오류가 없으면 녹취서에 확인인 또는 사법전자서명을 한 다음 녹취서를 그 기일의 변론(준비기일)조서 또는 증인신문조서·당사자신문조서 등의 뒤에 첨부하여 기록과 함께 보관한다(속기·녹음예규 13조의2 4항 전문, 11조 5항 전문). 제출받은 녹취서의 내용에 오류가 있다면 법원사무관

등은 속기자로 하여금 이를 바로잡도록 한다(13조의2 4항 전문, 11조 5항 후문).
녹취서 표지의 작성은 [전산양식 A1686, A1686-1]을 활용한다.

[전산양식 A1686] 녹취서(표지)

○ ○ 법 원

녹 취 서

확인인

사건번호	20 가
기 일	20 . . . 14:00
장 소	제○○호 법정
속기내용	증인 ○○○의 증언
총 면 수	○○면
비 고	

민사소송규칙 제35조의 규정에 따라 작성한 녹취서를 붙임과 같이 제출합니다.

20 . . .

속기자 ○○○ ㉠

제23장
조서의 작성 및 변론의 녹음 등

[전산양식 A1686-1] 녹취서(표지, 요지)

○ ○ 법 원

녹 취 서(요지)

확인인

사건번호	20 가
기 일	20 . . . 14:00
장 소	제○○호 법정
녹취내용	증인 ○○○의 증언
총 면 수	○○면
비 고	

민사소송규칙 제35조의 규정에 따라 작성한 녹취서를 붙임과 같이 제출합니다.

20 . . .
속기자 ○○○ ㉑

- ※ 이 녹취서는 진술의 주요한 부분만을 정리하여 기재하는 방식으로 작성되었습니다.
- ※ 당사자나 증인 등은 이 녹취서에 적힌 사항에 대해 이의를 제기할 수 있습니다. 이의가 제기되면 법원사무관등이 그 이의의 취지를 이 녹취서 또는 별도의 서면에 기재하거나 이 녹취서 중 해당 부분을 정정하여야 합니다.

(다) 녹취서에 대한 이의 및 정정절차

법원사무관등이 녹취서에 확인인 또는 사법전자서명을 하기 전에 녹취서의 표현에 오류가 있음이 발견된 때에는 앞서 설명한 바와 같이 법원사무관등이 속기자에게 그 오류를 바로잡도록 하면 된다.

그러나 확인인 또는 사법전자서명이 이루어진 다음에 당사자 등 소송관계인으로부터 녹취서에 적힌 사항에 대하여 이의가 제기된 때에는 법원사무관등이 녹취서에 그 취지를 적어야 한다(속기·녹음예규 13조의2 4항 후문). 이를 적는 방법은 ㉠ 이의의 대상이 된 당해 녹취서의 끝부분에 그 이의의 연월일과 이유를 덧붙여 이의한 취지를 적고 법원사무관등이 기명날인하는 방법, ㉡ 이의가 서면에 의한 때에는 녹취서의 끝부분에 아래의 기재례와 같이 적은 후 법원사무관등이 기명날인하는 방법, ㉢ 녹취서의 마지막 면 뒤에 위 ㉠ 또는 ㉡의 방법으로 기재한 다음 법원사무관등이 기명날인한 서면을 첨부하는 방법이 가능하다.

[기재례]

원고

별지 이의신청서 기재와 같이 이 녹취서 기재에 관하여 이의.

2000. 6. 7.

법원사무관 ○○○ ㉑

한편 법원사무관등이 확인인 또는 사법전자서명을 한 후에 소송관계인의

이의제기 등으로 녹취서 기재에 오류를 발견한 때에는 위와 같은 이의의 취지를 기재할 필요 없이 조서정정절차에 준하여 기재를 정정한다(속기·녹음예규 13조의2 4항 후문). 아래의 기재례와 같이 녹취서의 끝에 정정의 취지를 기재하거나 정정의 대상이 된 녹취서 부분에 ‘재일 85-1 재판서 기타 법원의 소송서류 중 오자정정요령’에 따라 기재를 정정할 수 있다.

[기재례]

원고의 이의신청에 따라, 이 녹취서의 제3면 제5행 기재의 “○○○”을 “xxx”로 정정한다.

2000. 6. 7.

법원사무관 ○○○ ㉠

(2) 요약조서

민사소송규칙 36조 2항은 조서의 일부로 삼는 녹음(속기)을 한 경우라도 재판장이 법원사무관등으로 하여금 당사자, 증인, 그 밖의 소송관계인의 진술 중 중요한 사항을 요약하여 조서의 일부로 기재할 수 있도록 규정하고 있다. 변론을 녹음하여 그 녹음물을 조서의 일부로 삼은 경우에도 해당 기일의 형식적 기재사항과 녹음명령의 고지 및 녹음물을 표시한 변론(준비기일)조서나 증인신문조서·당사자신문조서는 작성된다. 따라서 녹음을 하여 당사자, 증인 등 소송관계인의 진술을 그대로 기록하는 한편 그 진술 중 중요한 사항(가령 기일에서 해당 사건에 관하여 당사자 쌍방과 재판장이 협의하여 정리한 핵심적 쟁점사항이나 이에 관한 자백이나 증인의 증언요지 등)을 정리하여 기재해두면, 녹음물이 갖는 사후청취의 곤란성이나 종전 변론내용 파악의 어려움 등의 단점을 보완할 수 있다.

이는 민사소송법 154조 4호에서 정한 ‘재판장이 적도록 명한 사항과 당사자의 청구에 따라 적는 것을 허락한 사항’을 조서에 기재하는 것과 본질적으로 다르지 아니하다. 즉, 요약조서는 변론(준비)조서나 증인등신문조서와 별도로 작성하는 조서가 아니라, 원래 작성하는 조서에 녹음물 중 중요한 사

항을 요약하여 기재한 부분을 강조하는 의미이다.

요약조서의 기재는 속기자가 참석하지 않은 상태에서 증인신문·당사자신문 등이 아닌 변론절차나 변론준비절차를 녹음하는 경우에 유용한 기록방법이 될 수 있다. 다만 재판장은 기일 중에 법원사무관등에게 요약조서의 기재사항을 지시함이 바람직하다.

요약조서의 양식과 기재례는 [전산양식 A1658, A1658-1]과 같다.

한편 법원사무관등은 요약조서의 작성을 위하여 조서의 일부가 되는 전체 녹음물(기본 녹음물) 중 일부만을 발췌한 별도의 녹음물(요약녹음물)을 생성하여, 이를 기본 녹음물과 함께 보관할 수 있다(속기·녹음예규 13조의4 2항). 중요한 진술을 요약하는 과정에서 그 표현의 문맥이나 의미가 변질되어 당사자로부터 이의가 제기될 우려가 있는 경우, 법정녹음시스템의 요약파일 생성기능을 활용하여 재판장이 중요하다고 지적하는 사항과 그에 관한 당사자, 증인 등 소송관계인의 진술을 보다 편리하면서도 정확하게 기록할 수 있도록 법원사무관등이 기본 녹음물의 일부만을 발췌한 별도의 요약녹음물을 생성할 수 있는 근거를 마련하고 이를 기본 녹음물과 함께 보관할 수 있도록 한 것이다. 이 경우 요약조서는 요약녹음물의 내용을 인용하는 방식으로 작성할 수 있다. 그 기재례는 [전산양식 A1658-2]와 같다. 이때의 요약녹음물은 녹음 등의 근거법령에 따라 조서의 일부가 되는 녹음물로 본다(3항).

[전산양식 A1658] 변론조서(요약)

○ ○ 법 원
변 론 조 서(요약)

차

사 건 20 가

재판장 판사

판 사

판 사

법원사무관

기 일 : 20 . . . :

장 소 : 제○호 법정

공개여부 : 공 개

고지된

선고기일 : 20 . . . :

사건과 당사자의 이름을 부름

원 고 대리인 변호사 ○○○

출석

피 고 대리인 변호사 ○○○

출석

재판장 판사

민사소송법 제159조 제1항의 규정에 따라 변론의 내용을 녹음할 것을 명하고 당사자에게 이를 고지

원 고

소장 진술

피 고

20○○. ○. ○. 자 답변서 진술

【쟁점】 갑 제2호증의 작성경위

원 고

○○○이 갑 제2호증에 서명할 때 피고가 이를 허락하거나 위임을 한 바는 없다. 다만 서명할 때 원고와 피고도 함께 있었고, 적극적으로 반대의 의사를 표시하거나 제지한 적은 없었다.

그 밖의 변론의 내용은 법정녹음시스템의 녹음파일(고유번호: 123456789102)과 같다. 증거관계 별지와 같음(원고 서증 등)

속 행

법원사무관 ○○○

재판장 판사 ○○○

민소 159①, ②, 민소규 36②

제23장

조서의 작성 및 변론의 녹음 등

[전산양식 A1658-1] 증인신문조서(요약)

○ ○ 법 원

증 인 신 문 조 서(20 . . .차 변론조서의 일부, 요약)

사 건 20 가
증 인 이 름
생 년 월 일
주 소

재판장 판사

증인에게 선서의 취지를 명시하고 위증의 벌을 경고한 다음, 별지 선서서에 의하여 선서를 하게 하였다.
다음에 신문할 증인의 재정을 명하였다.

【쟁점】 원고의 아버지인 ○○○이 원고에게 증여한 2억 원으로 이 사건 회사를 설립하였는지 여부

1. ○○○은 ○○건설이 서울 ○○동에 건축한 ○○아파트 내 상가 ○호를 원고에게 주려 하였으나 피고가 ○○건설 임직원의 반대의견을 일으켜 ○○○은 위 점포를 원고에게 주지 못한 채 일부분양하였고, 그 대금은 7억 원 정도였다.
2. ○○○과 어머니의 소유인 토지가 ○○아파트의 부지에 포함되었기 때문에 위 점포의 일반분양대금은 토지대금으로 ○○○나 어머니에게 지급되었다는 말을 들은 바 있다.
3. ○○○이 위 점포 분양대금 7억 원 중 2억 원으로 원고를 위해 ○○회사를 설립하도록 피고에게 지시하였다.

증인에 대한 신문내용은 법정녹음시스템의 녹음파일(고유번호: 123456789101)과 같다.(또는 증인에 대한 신문내용은 별지 속기록의 기재와 같다.)

법원사무관 ○○○
재판장 판사 ○○○

[전산양식 A1658-2] 증인신문조서(요약)

○ ○ 법 원

증 인 신 문 조 서(20 . . . 차 변론조서의 일부, 요약)

사 건 20 가
 증 인 이 름
 생 년 월 일
 주 소

재판장 판사

증인에게 선서의 취지를 명시하고 위증의 벌을 경고한 다음, 별지 선서서에 의하여 선서를 하게 하였다.
 다음에 신문할 증인의 재정을 명하였다.

【쟁점】 원고의 아버지인 ○○○이 원고에게 증여한 2억 원으로 이 사건 회사를 설립하였는지 여부

증인에 대한 신문내용 중 위 쟁점과 관련된 부분의 내용은 법정녹음시스템의 녹음파일(고유번호: 123456789103)과 같다.

그 밖의 증인에 대한 신문내용은 법정녹음시스템의 녹음파일(고유번호: 123456789101)과 같다.

법원사무관 ○○○
 재판장 판사 ○○○

민소 159①, ②, 민소규 36②

제23장

조서의 작성 및 변론의 녹음 등

(3) 요지조서

(가) 요지조서를 작성하는 경우

2002년 개정 민사소송법은 녹음물(속기록)이 조서의 기재 대신하는 경우에 녹음된 증인신문절차 등에 관여한 바 없는 후임재판부나 상소심재판부가 녹음물만으로 증언 등의 뜻을 명확하게 이해하기 어려운 경우가 많을 수

있고, 그 요지도 파악하기 어려울 수 있음을 감안하여, 소송이 완결되기 전까지 당사자가 신청하거나 그 밖에 대법원규칙이 정하는 때에는 녹음물 등의 요지를 정리하여 조서를 작성하고, 조서가 작성된 경우에 재판이 확정되거나 양쪽 당사자의 동의가 있으면 녹음물 등을 폐기할 수 있도록 규정하였다(민소 159조 3항, 4항). 이에 따라 2014년 개정 전 민사소송규칙은 당사자의 신청이 있는 때와 더불어 상소가 제기된 때와 그 밖에 재판장이 상당한 이유가 있다고 인정하는 때에 위와 같이 요지를 정리한 조서(요지조서)를 작성하도록 규정하였다(구 민소규 36조 3항). 독립된 조서가 아니라 원래 작성하는 조서 중 특정 기재 부분을 강조하는 의미의 요약조서와 달리, 요지조서는 원래의 조서와 독립적으로 작성하게 된다. 그러나 이러한 요지조서는 기일 후 상당한 기간이 지난 후에야 녹음물을 청취하여 증언 내용을 정리하게 된다는 점에서 그 작성이 매우 번거로웠고, 그 작성부담이 녹음제도의 활용 확대를 저해하는 요인으로 지목되기도 하였다.

이러한 문제를 극복하기 위하여, 2014년 개정 민사소송규칙은 법률이 정한 범위 내에서 요지조서의 작성범위를 축소하여 ㉠ 민사소송법이 정한 바와 같이 ‘소송이 완결되기 전까지 당사자가 신청한 때’(민소 159조 3항) 외에 ㉡ 상소가 제기된 때(민소규 36조 3항 1호), ㉢ 법관이 바뀔 때(2호)에만 요지조서를 작성하도록 하되, 위 ㉡, ㉢의 경우로서 앞서 설명한 녹음물의 보완적 기록방법, 즉 요약조서의 기재가 있거나 녹취서(녹음과 속기를 병행한 경우 등에는 속기록)가 작성된 때에는 요지조서를 작성하지 않을 수 있도록 규정하였다(36조 3항 단서).

증인신문절차나 당사자신문절차에 대하여 녹음을 하는 경우에는 앞서 설명한 바와 같이 원칙적으로 녹취서가 작성되므로, 이러한 사건에 대하여는 상소가 제기되거나 법관이 바뀌더라도 요지조서를 작성할 필요가 없게 된다. 물론 증인신문절차 등의 경우에도 몇 가지 예외적인 상황에서는 녹취서가 작성되지 않을 수 있는데, 이러한 경우라도 중요한 사항을 요약하여 조서

에 기재해두거나 요약녹음물을 활용하여 요약조서를 작성한 때에는 상소가 제기되거나 법원이 바뀌더라도 요지조서를 작성할 필요가 없다.

소송이 완결되기 전까지 당사자가 요지조서의 작성을 신청한 때에는 녹취서(속기록) 또는 요약조서의 기재가 있더라도 요지조서를 작성하여야 하나, 이미 녹취서가 작성된 경우라면 당사자가 요지를 정리한 조서의 작성을 별도로 신청할 실익이 크지 않을 것이다.

(나) 작성방법

요지조서를 작성할 때에는 재판장의 허가를 받아 속기록이나 녹취서 가운데 필요한 부분을 그 조서에 인용할 수 있다(민소규 36조 4항). 변론 당시의 법원사무관등이 조서를 작성할 수 없는 특별한 사정이 있는 때에는 당해 사건에 관여한 다른 법원사무관등이 작성할 수 있다(5항). 가령 녹음 당시 참여하였던 법원사무관등이 인사이동 등으로 교체된 경우에는 요지조서를 해당 사건을 인계한 재판부의 법원사무관등이 작성할 수 있다.

이처럼 요지조서를 작성한 경우에 그 조서는 기본이 되는 변론(준비기일) 조서 뒤에 편철하고, 녹음물은 소송기록과 함께 보관하여야 한다(속기·녹음예규 14조 1항 1문). 요지조서가 작성된 이후에 기록과 함께 보관하는 녹음물은, 재판이 확정된 경우에는 기록을 보존하는 법원의 법원사무관등이 폐기할 수 있고, 확정되기 전이라도 양쪽 당사자의 동의가 있거나 폐기한다는 통지를 받은 날부터 2주 이내에 이의를 제기하지 아니하여 동의한 것으로 간주하는 경우에도 폐기할 수 있다(민소 159조 4항). 진술내용이 포함된 조서가 작성된 이상 중복하여 녹음물을 보관할 필요가 없다는 취지의 조항으로 이해할 수 있다. 다만 변론의 속기·녹음에 관한 업무처리요령은 법원사무관등이 참여하지 않은 기일에서 조서의 일부가 된 녹음물과 조서에 인용된 속기록이나 녹취서는 소송기록 보존기간 종료 시까지 폐기하여서는 아니 된다고 규정하여(속기·녹음예규 14조 2항 단서), 폐기 대상을 법률보다 제한하고 있으므로, 실제로 보존기간 종료 전에 폐기 대상이 되는 것은 민사소송법 159

조 1항에 따른 직권·신청에 의한 녹음물과 민사소송법 152조 1항에 따라 법원사무관등의 참여를 갈음하기 위해 생산하였으나 조서의 일부로 삼지는 않은 녹음물(이 경우 다음 기일의 종료 이전에 조서에 대한 이의가 없다면 바로 폐기할 수 있다. 속기·녹음예규 7조 1항, 2항)에 한정된다.

요지조서의 양식 및 기재례는 [전산양식 A1658-3]과 같다.

[전산양식 A1658-3] 증인신문조서

○ ○ 법 원

증 인 신 문 조 서(20 . . .차 변론조서의 일부)

사	진	20	가						
증	인	이	름						
		생	년	월	일				
		주	소						

이 조서는 민사소송법 제159조 제3항, 민사소송규칙 제36조에 의하여 녹음물(속기록)의 요지를 정리하여 작성하였다.

판 사

증인에게 선서의 취지를 명시하고 위증의 벌을 경고한 다음, 별지 선서서에 의하여 선서하게 하였다.

다음에 신문할 증인은 법정 안에 있지 아니하였다.

원고 대리인

문 :

답 :

민소 154, 159, 320, 321, 328

(4) 녹음과 속기를 병행하여 작성된 속기록

법원은 필요하다고 인정하는 경우나 당사자의 신청이 있고 그 신청에 따르지 아니할 특별한 사유가 없는 경우에 변론의 전부 또는 일부에 대한 녹음과 속기를 병행하여 그 녹음물과 속기록을 조서의 일부로 삼을 수 있다(민

소 159조 1항, 2항, 283조 2항). 법원이 녹음과 속기의 병행을 명한 경우에 녹음이 실시됨과 아울러 속기자도 법정에 참석하여 해당 변론(준비)기일 중에 당사자 등 소송관계인이 진술한 바를 속기한다. 법원 내에서의 효율적 업무 처리나 속기자의 업무가중 측면을 고려하여, 실무에서는 위와 같은 병행보다는 녹음과 녹취서에 의한 보완적 기록방법이 주로 활용되고 있다. 녹취서는 속기자의 법정참석이 필수적이지 않고, 사후작성도 가능하기 때문이다.

녹음과 속기가 병행되어 조서의 일부로 삼을 수 있는 녹음물과 속기록이 동시에 존재하는 경우, 재판장은 그중 어느 하나를 조서의 일부로 삼을 수 있다.

이때 재판장이 녹음물을 조서의 일부로 삼으면 조서의 일부가 되지 못한 속기록의 보관이나 이의·정정 등에 관해서는 녹취서에 준하여 처리하고(속기·녹음예규 13조의3, 11조 4항, 13조의2 4항), 그 속기록은 소송기록의 일부로서 민사소송법 162조에 따라 열람·복사의 대상이 된다. 만일 재판장이 녹음물과 속기록 중 속기록을 조서의 일부로 삼으면, 조서의 일부가 되지 못한 녹음물은 조서의 일부가 되는 녹음물처럼 보관되고, 열람·복사의 대상이 될 수 있다(속기·녹음예규 13조의3, 11조 1항, 2항, 12조).

3. 법원사무관등의 참여 없이 열린 기일의 녹음 등

법원사무관등의 참여 없이 변론(준비)기일을 열기 위한 전제로서 녹음(속기)이 이루어진 경우에도, 재판장의 허가를 받아 그 녹음물(속기록)을 조서의 일부로 삼을 수 있다(민소규 36조 1항 전문). 따라서 법원사무관등의 참여 없이 변론(준비)기일을 연 경우에는 그 녹음물(속기록)을 조서의 일부로 삼는지 여부에 따라 두 가지 유형이 있게 되는데, 그중 녹음물(속기록)을 조서의 일부로 삼는 경우(위 녹음 등 유형분류표 중 ㉔-2의 경우)의 보관방식이나 그 밖의 절차에 관하여는 민사소송법 159조에 의한 녹음(속기)의 경우에 관한 민사소송규칙 34조 1항, 2항이 준용되고(36조 1항 후문), 그 구체적인 방법은

앞의 2항에서 설명한 바와 같다. 따라서 이하에서는 그 녹음물(속기록)을 조서의 일부로 삼지 아니하는 경우(위 유형분류표 중 ②-1의 경우)에 관해서만 설명하기로 한다.

가. 녹음(속기)의 요건

법원사무관등은 변론기일에 참여하여 기일마다 조서를 작성함이 원칙이지만, 변론을 녹음(속기)하는 경우 그 밖에 이에 준하는 특별한 사정이 있는 경우에는 법원사무관등의 참여 없이 기일을 열 수 있고, 이는 변론준비기일에도 준용된다(민소 152조 1항, 283조 2항). 즉 법원사무관등을 변론(준비)기일에 참여시키지 아니하기 위한 요건 중 하나로서 녹음(속기)이 실시된다.

이러한 녹음(속기)을 할 것인지(또는 이를 근거로 법원사무관등을 기일에 참여시키지 아니할 것인지) 여부의 판단은 재판장의 권한이며, 당사자에게는 신청권이 없다. 다만 통상 이러한 녹음(속기)은 법원사무관등의 참여가 없는 예외적인 기일진행을 전제하는 것이므로, 녹음(속기)에 기초한 재판장의 설명만으로 조서작성이 충분히 가능한 경우에 주로 활용될 것이다.

녹음(속기)을 하지 않더라도 이에 준하는 특별한 사정이 있는 경우에는 법원사무관등의 참여 없이 기일을 열 수 있는데, 이때에도 성질에 반하지 않는 한 녹음 등의 경우와 같은 절차에 의하여 처리하여야 한다(속기·녹음 예규 8조).

특히 실무상 변론기일은 거의 예외 없이 법원사무관등이 참석하는 반면 변론준비기일은 민사소송법 152조 1항 단서를 근거로 참여관의 참석 없이 기일을 진행하는 비중이 높다. 이때 민사소송법이 정한 녹음(속기)을 실시함이 바람직하겠으나, 실제 변론이 이루어지는 것이 아니라 쟁점, 증거의 정리를 목적으로 하는 변론준비기일의 성격에 비추어, 기일에서 재판장이 사건별로 조서 기재사항을 메모하는 정도로 녹음, 속기에 준하는 사정을 인정해도 무리가 없을 것이다. 필요에 따라서는 뒤에서 설명하는 조서작성의 편의

를 위한 녹음을 활용하는 것도 가능하다고 할 것이다.

나. 녹음(속기)의 절차

녹음(속기)을 하면서 법원사무관등을 참여시키지 아니하고 변론(준비)기일을 여는 경우, 재판장은 그 기일을 시작할 때에 그 취지를 당사자에게 고지하여야 한다(속기·녹음예규 4조). 당사자에게 법원사무관등의 참여 없이 개정한다는 것과 뒤에서 보는 바와 같은 절차로 그 기일의 조서가 작성됨을 미리 알려주기 위함이다. 다만 그러한 고지가 없더라도 재판장의 설명에 따라 법원사무관등이 조서를 작성한 이상 조서의 효력에는 영향이 없다.

녹음은 법정녹음시스템 또는 다른 녹음저장매체를 이용하여 할 수 있는데(속기·녹음예규 5조 1항), 법정녹음시스템에 의할 때에는 사건마다 별도로 법정녹음시스템을 이용하여 녹음하고, 그 결과 생성되는 전자파일에는 검색이 가능하도록 고유번호를 부여하여 법정녹음시스템의 서버나 이에 준하는 서버에 보관한다(5조 1항 단서, 11조 1항 본문). 법정녹음시스템을 이용할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우에는 다른 녹음저장매체를 사용할 수 있는데(5조 1항 본문, 11조 1항 단서), 1개의 녹음테이프 등 저장매체로 연속적으로 진행되는 여러 사건의 변론을 함께 녹음할 경우에는 혼동을 피하기 위하여 재판장은 사건마다 변론을 시작할 때 사건번호를 밝혀 녹음하거나 그 밖에 적당한 방법으로 녹음 부분을 특정할 수 있도록 조치하여야 한다(5조 2항).

그리고 법원사무관등은 작성된 녹음물(속기록)을 다음에서 보는 바와 같은 절차에 따라 폐기할 때까지 적절한 방법으로 보관하여야 한다(속기·녹음예규 5조 3항).

다. 조서의 작성 등

위와 같은 절차를 거쳐 녹음(속기)을 하는 경우에 법원사무관등은 기일이 끝난 뒤에 지체 없이 재판장의 설명에 따라 조서를 작성하고 그 취지를 덧

붙여 적어야 한다. 그 조서의 양식은 [전산양식 A1653]과 같다(민소 152조 3항, 속기·녹음예규 6조).

이러한 녹음이나 속기는 법원사무관등의 참여 없이 변론(준비)기일을 연 경우에 조서 작성의 정확성을 확보하기 위한 조치이므로, 이 조서가 작성된 후 그다음 기일의 종료 시까지 관계인이 민사소송법 164조의 규정에 의한 조서에 대한 이의를 제기하지 아니하면 법원사무관등은 그 녹음물(속기록)을 폐기할 수 있다. 다만 다음 기일의 종료 이전에 관계인의 조서에 관한 이의가 있으면 그 이의에 관한 업무처리가 종결된 다음에 녹음물(속기록)을 폐기할 수 있다(속기·녹음예규 7조 1항, 2항). 이미 조서가 작성되고 이의가 없거나 이의에 대한 절차가 종료되었다면 법원사무관등으로서는 그 녹음물(속기록)을 더 이상 보관할 이유가 없으므로 대부분의 경우 바로 폐기하게 될 것이다.

라. 녹음물 등의 열람·복사 불허

법원사무관등의 참여 없이 기일을 열기 위한 전제로서 이루어지는 녹음·속기를 한 경우에 그 녹음물(속기록)은 별도로 조서의 일부로 삼는 조치가 이루어지지 않은 이상 위와 같이 조서작성의 편의를 위한 것이지 그 자체가 소송기록의 일부를 이루는 것은 아니다. 따라서 그 녹음물(속기록)에 관하여 당사자나 이해관계인은 민사소송법 162조의 규정에 따른 열람·복사를 신청할 수 없음이 당연하다. 변론의 속기·녹음에 관한 업무처리요령도 이러한 취지의 규정을 두고 있다(속기·녹음예규 7조 3항).

4. 조서작성의 편의를 위한 녹음 등(사무보조용 녹음 등)

재판장 또는 법원사무관등이 조서 작성의 편의와 조서 기재 내용의 정확성을 보장하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에도 녹음(속기)을 할 수 있다. 재판장의 허가만 있다면 녹음이 가능하므로(법조 59조) 이 경우에는 별도

의 명령 등의 절차도 필요 없고 당사자에게 그 사실을 고지하여야 하는 것도 아니다. 이러한 녹음(속기)을 한 경우에 그 녹음물 또는 속기록은 조서의 일부를 이루는 것도 아니고 조서작성 업무에 보조적으로 이용하기 위한 것일 뿐이므로, 법원사무관등은 그 녹음물(속기록)을 기록과 분리하여 보관함으로써 열람·복사의 대상이 되지 않도록 유의하여야 한다. 또한 법원사무관등은 조서가 작성된 경우에는 소송관계인의 개인정보보호와 소송절차의 안정을 위하여 조서작성의 편의를 위한 녹음물(속기록)을 즉시 폐기한다(속기·녹음예규 16조). 녹음 등의 방법도 재판장 또는 법원사무관등이 적당하다고 인정하는 방법으로 하면 된다.

한편 속기자가 기일에 참여하여 속기록을 작성하고 사실상 이를 그대로 조서화하는 경우에는 ‘사무보조용 속기’보다는 앞의 2항에서 설명한 민사소송법 159조 등의 규정에 의한 속기로 처리함이 바람직할 것이다.

제23장